

제11장 채권압류와 회생·파산

제11장 채권압류와 회생·파산

제1절 채권압류와 회생절차

I. 개설

회생절차란, 재정적 어려움으로 인하여 파탄에 직면하였으나 경제적으로 갱생의 가치가 있는 채무자에 대하여 채권자, 주주 기타 이해관계인의 법률관계를 조정하여 그 사업의 정리 재건 및 효율적인 회생을 도모하는 제도를 말한다[채무자회생 및 파산에 관한 법률(이하 '채무자회생법'이라고 한다) 제21조 참조].¹⁾

그런데 회생절차의 개시신청이 있는 경우 그 신청만으로는 아무런 법적 효과가 발생하지 않기 때문에 개시신청과 개시결정 사이에 방만한 회사운영, 재산의 은닉과 산일(散逸), 경영상의 혼란 등을 방지하고, 채무자재산을 보전하기 위한 제도로 채무자재산에 대한 민사집행과 관련하여 보전처분과 다른 절차의 중지명령, 강제집행 등의 취소명령, 그리고 포괄적 금지명령제도 등이 마련되어 있다(채무자회생법 제43조, 제44조, 제45조). 따라서 회생절차의 개시신청이 있더라도 회생절차개시결정이 있기 전에는 법원의 중지명령, 취소명령, 포괄적 금지명령 등이 없는 한 채무자의 재산에 대하여 강제집행이 가능하다.

또한 집행권원 취득 후 회생절차가 개시된 경우 승계집행문을 부여받을 필요가 없다. 즉 채무자 회사의 근로자들이 임금 등 채권에 기하여 회사의 제3채무자에 대한 채권에 대하여 압류 및 추심명령을 받고 적법한 통지까지 마친 후에 채무자 회사에 대하여 회생절차가 개시되었다 하더라도 종전 회사를 채무자로 하여 이루어진 압류 및 추심명령은 별도의 수계나 승계집행문 또는 경정 없이도 제3채무자나 채무자에 대하여 효력을 가진다.²⁾

1) 회생절차는 일본 회사갱생법(會社更生法)을 모방한 입법이고, 일본 회사갱생법은 당시 미국 연방파산법(Bankruptcy Code, U. S. C. Title 11) 제11장 「회사의 갱생(Corporate Reorganization)」을 계수한 입법이라고 할 수 있다.

2) 대법원 1996. 9. 24. 선고 96다13781 판결

II. 회생절차개시결정 전의 경우

1. 보전처분과 강제집행

가. 보전처분의 의의

1) 보전처분은 회생절차개시 신청이 있는 후 개시신청에 관한 개시결정 또는 기각결정이 있기 전까지의 사이에 법원이 이해관계인의 신청³⁾ 또는 직권으로(당사자의 신청이 없는 경우) 채무자의 업무 및 재산에 대하여 그 권리를 보전하기 위하여 명하는 잠정적인 처분을 말한다.⁴⁾ 즉 회생절차개시 결정이 있으면 채무자의 사업경영과 재산의 관리·처분에 관한 권리는 관리인에게 전속되고 이해관계인의 채무자에 대한 개별적 권리행사도 금지되지만, 이러한 효과는 절차개시의 신청에 따라 회생절차개시 여부를 심리하고 있는 단계에서는 아직 발생하지 아니한다. 따라서 이 단계에서 채무자가 경영을 방만히 하거나 재산을 숨길 우려가 있고, 또한 이해관계인에 의한 권리행사로써 불공평한 분배가 이루어질 가능성이 있으므로 법원은 회생절차개시의 결정을 하기 전이라도 이해관계인의 신청에 의하여 또는 직권으로 채무자의 업무와 재산에 관하여 가압류, 가처분 기타 필요한 처분을 명하거나 보전관리인의 관리를 명할 수 있도록 한 것이다(채무자회생법 제43조 제1항).⁵⁾

2) 보전처분은 민사집행법상의 보전처분과는 다른 특수보전처분⁶⁾으로서 강학상

- 3) 채무자 외에 채권자, 주주이지만 하면 회생절차개시신청권이 없는 소액채권자나 소액주주도 신청권이 있다고 본다. 이 경우 신청인은 회생절차개시원인에 대한 소명은 물론 보전의 필요성에 대해서도 소명하여야 한다.
- 4) 광의의 보전처분이란 법원이 관리자의 집행보전과 손해방지를 목적으로 행하는 잠정적인 조치를 명하는 내용의 재판 전부를 말하며, 여기에는 민사소송에서의 각종 보전처분 외에 비송사건에서의 보전처분 및 공법상의 보전처분까지 모두 포함한다. 예컨대, 민사조정법상의 조정 전의 처분(같은 법 제21조), 가사소송법상의 가압류·가처분(같은 법 제63조), 공법상의 보전처분(행정소송법 제23조), 민사소송법상의 응급처분으로서의 가처분 내지 잠정처분(같은 법 제500조, 제501조, 제502조), 가등기가처분(부동산등기법 제37조), 채무자회생법상의 가압류·가처분 그 밖에 필요한 보전처분(같은 법 제43조, 제114조, 제323조, 제351조, 제592조) 등 특별법에 의한 임시처분 등이 있다. 협의의 보전처분이란 민사집행법 제4편에 규정된 가압류와 가처분만을 가리키는 용어로 쓰이고 있다.
- 5) 채무자회생법은 제43조에 의한 보전처분 이외에도 제114조에 의한 법인의 이사 등의 재산에 대한 보전처분을 규정하고 있다. 그러나 제114조에 의한 보전처분은 이사 등에 대한 손해배상청구권보전을 위한 제도임에 반하여, 제43조에 의한 보전처분은 채무자의 사업과 재산에 대한 제도이므로 서로 다른 제도이고, 양 보전처분은 서로 병존할 수 있다.
- 6) 채무자회생법상의 보전처분은 ① 본안법원의 관찰에 속하고, ② 신청인에 대한 상대방이 항상 존재하여야 하는 것이 아니며, ③ 본안법원이 그 직권으로 명할 수 있을 뿐만 아니라, ④ 처분 후에도 직권으로도 이를 취소·변경할 수 있기 때문에 민사집행법상의 가압류, 가처분에 관한 규정이 같은 법상의 보전처분에도 그대로 적용된다고 볼 수 없다.

처분금지 보전처분, 업무제한 보전처분, 조직법상의 보전처분으로 나누어 설명되고 있다.

그 중 업무제한 보전처분과 처분금지 보전처분은 채무자회생법 제43조 제1항의 채무자의 업무 및 재산에 관한 보전처분을 말하고, 조직법상의 보전처분은 채무자회생법 제43조 제2항의 보전관리인에 의한 관리명령(보전관리명령)을 말한다. 또한 보전처분을 조문체계상 협의의 보전처분과 광의의 보전처분으로 나누어 볼 수 있고, 그 중 협의의 보전처분은 채무자회생법 제43조 제1항에 규정된 보전처분만을 의미하는데 반하여, 광의의 보전처분은 채무자회생법상의 협의의 보전처분과 보전관리명령을 포함하는 개념이다. 통상 보전처분이라고 하면 협의의 보전처분만을 의미한다.

나. 보전처분과 강제집행의 관계

회생절차가 신청된 후 보전처분을 받은 경우 채무자의 재산을 처분하는 것이 제한되지만, 이 보전처분은 채권자의 강제집행을 저지하는 효과는 없다.⁷⁾ 따라서 채무자가 소송이나 강제집행을 저지하고자 하는 경우에는 별도의 중지명령이나 포괄적 금지명령을 받아야 한다.⁸⁾

2. 중지명령과 강제집행

가. 의의

법원은 회생절차개시의 신청이 있는 경우 필요하다고 인정하는 때에는 이해관계인의 신청에 의하여 또는 직권으로 회생채권이나 회생담보권에 기한 강제집행, 가압

7) 대법원 1992. 10. 27. 선고 91다42678 판결(변제금지 보전처분과 특정된 물건과 권리에 관하여 처분금지 보전처분을 한 경우 처분금지 보전처분에서 제외되어 있는 물품에 대하여는 변제금지 보전처분만으로 양도담보권자의 담보권 실행을 저지하는 효과가 없다고 판시); 대법원 2007. 5. 10. 선고 2007다9856 판결[구 화의법 제20조 제1항(현재 채무자회생법 제43조 제1항과 같은 취지의 규정)의 규정에 의한 보전처분으로서 채무자에 대하여 채무변제를 금지하였다 하더라도 그 처분의 효력은 원칙적으로 채무자에게만 미치는 것이므로 채무자가 임의로 변제하는 것이 금지될 뿐이고, 채권자가 이행지체에 따른 해지권을 행사하는 것까지 금지되는 것은 아니라고 판시]

8) 대법원 1993. 9. 14. 선고 92다12728 판결 【판결요지】회사정리절차개시의 신청을 받은 법원이 그 결정을 하기에 앞서 회사정리법 제39조 제1항의 규정에 의한 보전처분으로서 회사에 대하여 채권자에 대한 채무의 변제를 금지하였다 하더라도 그 처분의 효력은 원칙적으로 회사에만 미치는 것이어서 회사가 채권자에게 임의로 변제하는 것이 금지될 뿐 회사의 채권자가 강제집행을 하는 것까지 금지되는 것은 아니고, 다른 한편 정리절차가 개시된 후에도 정리채권자 또는 정리담보권자는 회사정리법 제162조에 정한 바에 따라 정리절차에 의하지 아니하고 상계를 할 수 있음이 원칙인 점에 비추어 볼 때 보전처분만이 내려진 경우에는 회사의 채권자에 의한 상계가 허용되지 않는다고 할 수 없다.

류, 가치분 또는 담보권 실행을 위한 경매절차로서 채무자의 재산에 대하여 이미 행하여지고 있는 것, 채무자의 재산에 관한 소송절차 또는 채무자의 재산에 관하여 행정청에 계속하고 있는 절차의 중지를 명할 수 있다(채무자회생법 제44조 제1항 제1호 내지 제4호).

다만 강제집행, 가압류, 가치분 또는 경매절차에 관하여는 회생채권자 또는 회생담보권자에게 '부당한 손해를 끼칠 염려'가 없어야 한다(채무자회생법 제44조 제1항 제2호). 여기서 '필요하다고 인정하는 때'란 그 절차의 진행을 그대로 방치하면 회생절차개시결정까지 사이에 채무자재산이 처분되거나 또는 채권자간의 형평을 해치는 결과가 되어 회생의 장애로 될 가능성이 높은 경우를 말한다. 따라서 회생절차신청을 기각할 것이 분명한 경우에는 중지명령신청을 받아들여서는 아니 된다.⁹⁾

나. 강제집행 등의 중지

회생채권 또는 회생담보권으로 될 채권에 기한 강제집행·가압류·가치분·담보권 실행을 위한 경매절차로서 채무자의 재산에 대하여 이미 행하여지고 있는 것에 한하여 중지할 수 있다(채무자회생법 제44조 제1항 제2호). 그러나 환취권¹⁰⁾에 기한 것이거나 공익채권¹¹⁾으로 될 채권에 기한 절차는 중지할 수 없다. 회생절차 개시결정 시기에 따라 공익채권과 회생채권의 한계가 정해지는 채권의 경우에는 집행채권 중의 일부라도 공익채권으로 될 채권이 '포함되어 있으면' 그 강제집행 등의 절차를 중지할 수 없는 것으로 해석된다.¹²⁾

다. 중지명령에 위반한 집행절차의 효력

중지명령에 위반하여 집행된 절차는 무효이지만, 그러한 집행행위의 외형을 제거하기 위하여는 집행방법에 관한 이의, 즉시항고 등을 제기하여야 한다. 중지명령은

9) 서울중앙지방법원 파산부 실무연구회, 회생사건실무(상), 박영사(2011), 96.

10) 관련판례 : 대법원 2014. 4. 10. 선고 2013다61190 판결【판결요지】동산의 소유권유보부매매는 동산을 매매하여 인도하면서 대금 완납 시까지 동산의 소유권을 매도인에게 유보하기로 특약한 것을 말하며, 이러한 내용의 계약은 동산의 매도인이 매매대금을 다 수령할 때까지 대금채권에 대한 담보의 효과를 취득·유지하려는 의도에서 비롯된 것이다. 따라서 동산의 소유권유보부매매의 경우에, 매도인이 유보한 소유권은 담보권의 실질을 가지고 있으므로 담보 목적의 양도와 마찬가지로 매수인에 대한 회생절차에서 회생담보권으로 취급함이 타당하고, 매도인은 매매목적물인 동산에 대하여 환취권을 행사할 수 없다.

11) 회생채무자에 대한 회생절차가 개시된 후 관리인의 공익채권 이행지체로 인하여 생긴 손해배상 청구권도 공익채권에 해당한다(대법원 2004. 11. 12. 선고 2002다53865 판결; 대법원 2011. 6. 24. 선고 2009다38551 판결).

12) 서울중앙지방법원 파산부 실무연구회, 위 회생사건실무(상), 98.

구체적인 절차를 계속하여 진행하려는 것을 중지시키는 효력밖에 없기 때문에 새로이 동종절차의 개시를 신청하는 것은 상관없다.

또한 중지명령은 당해 절차를 더 이상 진행시키지 않는다는 효력이 있을 뿐이고 이미 진행된 절차의 효력을 소급하여 무효로 만드는 것이 아니다. 따라서 이미 집행된 압류 등의 효력은 그대로 유지된다. 이를 회생계획인가 전에 실효시키고자 한다면 강제집행 등의 취소명령을 받아야 한다.

라. 집행장애사유

중지명령은 회생절차개시의 신청에 대한 결정이 있을 때까지 집행의 일시적 정지를 명하는 재판이므로 중지명령의 정본은 민사집행법 제49조 제2호가 정하는 ‘강제집행의 일시정지를 명한 취지를 적은 재판의 정본’에 해당한다.

채무자가 중지명령의 정본을 집행기관에 제출한 경우 집행기관은 그 이후 집행행위를 하지 아니하고 현상을 유지하면 되고(민집 제49조 제2호), 집행이 완료된 이후에 중지명령 정본이 제출된 경우에는 중지명령은 그 목적을 달성할 수 없게 되며, 이미 이루어진 집행행위는 그대로 효력을 유지하게 된다. 중지명령 정본이 제출되었음에도 불구하고 집행기관이 집행을 정지하지 아니하고 집행처분을 한 경우에는 이해관계인은 집행에 관한 이의신청 또는 즉시항고에 의하여 취소를 구할 수 있다.

3. 강제집행 등의 취소명령

법원은 채무자의 회생을 위하여 특히 필요하다고 인정하는 때에는 채무자(보전관리인이 선임되어 있는 때에는 보전관리인을 말한다)의 신청에 의하거나 직권으로 중지된 회생채권 또는 회생담보권에 기한 강제집행 등의 취소를 명할 수 있다. 이 경우 법원은 담보를 제공하게 할 수 있다(채무자회생법 제44조 제4항).

취소의 대상은 회생채권 또는 회생담보권에 기하여 행하여진 강제집행, 가압류, 가처분 또는 담보권 실행을 위한 경매절차이다. 법원의 취소명령으로 인하여 종전의 강제집행 등은 소급하여 그 효력을 잃는다.

4. 포괄적 금지명령과 강제집행

가. 개별적인 중지명령에 의해서 회생절차의 목적을 충분히 달성하지 못할 우려가 있다고 인정할 만한 특별한 사정이 있는 때에는 이해관계인의 신청이나 직권으로 개시결정시까지 모든 회생채권에 대하여 회생채권에 기한 강제집행, 가압류, 가처분

또는 담보권 실행을 위한 경매절차의 금지를 명할 수 있다(채무자회생법 제45조 제1항). 이를 포괄적 금지명령이라고 하고, 채무자회생법에서 신설된 제도이다.

이는 그 동안 법률행위별로 개별적인 중지명령만 인정되어 다수의 재산이 서로 다른 법원의 관할 지역에 산재한 경우 등에는 책임재산의 보전이 곤란하였으므로 이를 개선하려는 것으로서, 개별절차의 중지명령에 의하여도 회생절차의 목적을 충분히 달성하지 못할 특별한 사정이 있는 경우에 법원이 하나의 결정으로 모든 회생채권자 등에 대하여 회생채무자의 재산에 대한 강제집행 등의 금지를 명할 수 있도록 한 것이다.

나. 이러한 금지명령을 할 수 있는 경우는 채무자의 주요한 재산에 관하여, ① 채무자회생법 제43조 제1항의 규정에 의한 보전처분 또는 ② 채무자회생법 제43조 제3항의 규정에 의한 보전관리명령이 이미 행하여졌거나 포괄적 금지명령과 동시에 이러한 처분 또는 명령을 행하는 경우에 한한다(채무자회생법 제45조 제2항).¹³⁾ 포괄적 금지명령이 있는 때에는 채무자의 재산에 대하여 이미 행하여진 회생채권 또는 회생담보권에 기한 강제집행 등은 중지된다(채무자회생법 제45조 제3항).

다. 법원은 포괄적 금지명령이 있는 경우 회생채권 또는 회생담보권에 기한 강제집행 등의 신청인인 회생채권자 또는 회생담보권자에게 부당한 손해를 끼칠 우려가 있다고 인정하는 때에는 그 회생채권자 또는 회생담보권자의 신청에 의하여 그 회생채권자 또는 회생담보권자에 대하여 결정으로 포괄적 금지명령의 적용을 배제할 수 있다. 이 경우 그 회생채권자 또는 회생담보권자는 채무자의 재산에 대하여 회생채권 또는 회생담보권에 기한 강제집행 등을 할 수 있으며, 포괄적 금지명령이 있기 전에 그 회생채권자 또는 회생담보권자가 행한 회생채권 또는 회생담보권에 기한 강제집행 등의 절차는 속행된다(채무자회생법 제47조 제1항). 포괄적 금지명령은 채권자의 권리행사에 대한 큰 제약이므로 그 구제수단으로서 적용배제에 관한 규정을 둔 것이다.

III. 회생절차 개시결정 후의 경우

1. 강제집행신청 등의 금지와 절차의 중지

가. 회생절차 개시결정이 있는 때에는 그 개시결정의 효과로서 회생채권 또는 회

13) 이러한 제한을 둔 이유는 포괄적 금지명령이 하나의 결정으로 채권자들에게 강력한 효과를 미치기 때문이다.

생담보권에 기한 강제집행 등을 할 수 없고, 채무자의 재산에 대하여 이미 행한 회생채권 또는 회생담보권에 기한 강제집행 등은 중지된다(채무자회생법 제58조 제1항, 제2항).¹⁴⁾ 또한 회생절차 개시 후 회생채권 또는 회생담보권에 관하여는 특별한 규정이 없는 한 회생계획에 규정된 바에 따르지 아니하고는 변제하거나 변제받는 등 이를 소멸하게 하는 행위(면제를 제외한다)를 하지 못한다(채무자회생법 제131조, 제141조 제2항).

나. 개개의 강제집행절차가 종료된 경우에는 그 절차가 중지될 수 없는데, 부동산에 대한 금전집행은 매각대금이 채권자에게 교부 또는 배당된 때에 비로소 종료한다. 따라서 부동산경매절차에서 채무자 소유 부동산이 매각되고 매수인이 매각대금을 모두 납부하여 매각 부동산 위의 저당권이 소멸하였더라도 배당절차에 이르기 전에 (배당기일이 열리기 전에) 채무자에 대해 회생절차개시결정이 있었다면 저당권자는 회생절차 개시 당시 저당권으로 담보되는 채권 또는 청구권을 가진 채무자회생법 제141조에 따른 회생담보권자에 해당된다.¹⁵⁾ 따라서 이 경우는 집행절차가 중지되어야 하고 만일 이에 반하여 집행이 이루어졌다면 무효이고, 이후 채무자에 대한 회생계획인가결정이 있는 때에 중지된 집행절차는 효력을 잃는다.¹⁶⁾

다. 개시결정으로 인하여 금지되거나 중지되는 절차는 회생채권 또는 회생담보권에 의한 강제집행에 한하므로 앞서 본 대로 환취권(채무자회생법 제70조)¹⁷⁾ 또는 공익채권에 의한 강제집행이나 가처분은 금지나 중지의 대상이 아니다(통설).¹⁸⁾ 다만

14) 나아가 회생계획의 인가결정이 되면 중지된 강제집행은 효력을 잃는다(채무자회생법 제256조 제1항).

15) 2018. 11. 29. 선고 2017다286577 판결

16) 2018. 11. 29. 선고 2017다286577 판결

17) 관련판례 : 대법원 2014. 4. 10. 선고 2013다61190 판결 【판결요지】동산의 소유권유보부매매는 동산을 매매하여 인도하면서 대금 완납 시까지 동산의 소유권을 매도인에게 유보하기로 특약한 것을 말하며, 이러한 내용의 계약은 동산의 매도인이 매매대금을 다 수령할 때까지 대금채권에 대한 담보의 효과를 취득·유지하려는 의도에서 비롯된 것이다. 따라서 동산의 소유권유보부매매의 경우에, 매도인이 유보한 소유권은 담보권의 실질을 가지고 있으므로 담보 목적의 양도와 마찬가지로 매수인에 대한 회생절차에서 회생담보권으로 취급함이 타당하고, 매도인은 매매목적물인 동산에 대하여 환취권을 행사할 수 없다.

18) 공익채권은 회생절차에 의하지 아니하고 수시로 변제할 수 있기 때문이다(채무자회생법 제180조 제1항). 그리고 공익채권에 기하여 부동산에 관한 경매가 실행되는 경우에도 그 부동산에 관한 회생담보권은 그 효력을 잃지 아니하므로 회생담보권은 그 부동산의 매각대금에서 우선 변제를 받을 권리가 있다. 또한 회생담보권의 경우, 채무자회생법 제58조 제1항을 들어 경매를 절대적으로 허용할 수 없다는 반대견해도 있으나, 실무는 회생계획에서 경매절차 실행 권한을 부여한 경우에는 담보권 실행을 위한 경매가 가능하다고 보고 있다(경매절차 속행명령에 관한 채무자회생

공익채권에 기한 강제집행 또는 가압류가 회생에 현저하게 지장을 초래하고 채무자에게 환가하기 쉬운 다른 재산이 있는 때나 채무자의 재산이 공익채권의 총액을 변제하기에 부족한 것이 명백하게 된 때에는 법원은 직권 또는 관리인의 신청에 의하여 담보를 제공하거나 하지 아니하게 하고, 공익채권에 의한 강제집행 또는 가압류를 중지하거나 취소할 수 있다(채무자회생법 제180조 제3항).

라. 또한 앞서 본 중지명령의 경우와 동일하게 채무자의 재산에 대하여 행하는 것에 한하므로 제3자, 예컨대 연대채무자, 보증인, 물상보증인 등의 재산에 대하여 행하는 것¹⁹⁾은 금지, 중지되지 아니한다.²⁰⁾ 21) 다만 채무자의 채무자(즉 제3채무자)에 대한 채권집행(압류명령, 전부명령, 추심명령)은 채무자의 재산에 대한 강제집행이

법 제58조 제5항 참조).

공익채권 또는 회생담보권에 기하여 경매가 진행된 경우 그 배당의 실시방법에 관하여, 경매절차에서 공익채권 등에 기한 압류나 배당요구는 당해 부동산의 매각대금에서 변제를 받을 자를 정하는 것에 그치고 실질적인 변제절차는 일괄하여 회생채무자의 관리인이 하도록 모두 관리인에게 교부하여야 한다고 한다는 견해(제1설)와 이 경우 집행법원이 직접 회생담보권자나 공익채권자에게 지급하여야 한다는 견해(제2설)가 대립하고 있다. 제2설은 회생채권 중 회생절차 개시 전에 채납처분을 마친 조세 등 교부청구권자에게도 직접 지급하여야 한다고 보고 있다. 즉 회생절차 개시 전에 채납처분을 마친 조세 등 교부청구권자는 회생계획의 변제조건에 따라 일정 기간 조세채권의 변제기가 유예되고, 채납처분의 실행이 중지될 뿐(채무자회생법 제58조 제3항), 다른 회생채권의 경우와 달리 회생계획의 인가에 의해서도 그 채납처분이 실효되지 아니하므로(채무자회생법 제256조 제1항 본문, 제58조 제2항 제3호), 집행법원은 회생채무자의 관리인을 통하지 아니한 채 조세 등 교부청구권자에게 직접 지급하여야 한다는 것이다.

위 제1설에 의하면 매각대금을 전액을 회생채무자의 관리인에게 교부하여야 할 것이나, 제2설에 의하면 배당표 작성시 공익채권, 회생담보권 및 회생절차개시 전 채납처분을 마친 조세 등 채권은 집행법원이 직접 지급하여야 하므로 이를 구분하여 적고 나머지는 회생채무자의 관리인에게 교부하는 것으로 배당표를 작성하여야 할 것이다. 또한 제2설에 의할 경우 회생담보권과 공익채권 및 회생절차개시 전에 채납처분을 한 조세채권의 배당순위가 문제되는데, 그 배당순위도 근본적으로 민사집행법 제145조 제2항이 적용되므로 민법·상법, 그 밖의 법률에 의한 우선순위에 따라 배당하여야 한다. 그런데 회생채무자의 경우에는 채무자회생법 제180조 제2항에 '공익채권은 회생채권과 회생담보권에 우선하여 변제하여야 한다'고 규정하고 있으므로 이에 따라야 하나, 다만 이 조항은 공익채권은 회사의 일반재산으로부터 변제를 받는 경우에 우선한다는 의미일 뿐, 회생담보권이 설정된 특정재산의 매각대금으로부터도 우선변제를 받는다는 의미는 아니므로, 회생담보권이 설정된 재산 위에 공익담보권이 설정된 경우에는 회생담보권이 우선한다(대법원 1993. 4. 9. 선고 92다56216 판결).

19) 대법원 1984. 11. 15.자 84그75 결정【결정요지】경매목적물이 정리회사의 소유재산이 아니라 물상보증인의 재산이라면 회사정리법 제67조에 따른 경매절차의 금지 내지 중지조항이 적용될 정리가 아님은 동법 제240조 제2항에 의하여 명확하여 정리절차 개시에 의하여 물상보증인 소유부동산에 대한 경매절차가 어떠한 영향을 받는 것은 아니다.

20) 서울중앙지방법원 파산부 실무연구회, 위 회생사건실무(상), 155.

21) 대법원 1969. 4. 14.자 69마153 결정【결정요지】정리회사의 채권자가 정리절차에 참가하였다 하여 그 채권을 담보하는 제3자 소유의 부동산에 대한 담보권의 실행을 막을 수 없다.

기 때문에 금지·중지된다.²²⁾ 채무자에 대하여 행하여지더라도 그 인격적인 활동에 대하여 행하여지는 가처분, 예컨대 이사의 직무집행정지 또는 직무대행자선임 등은 금지, 중지의 대상이 아니다.²³⁾

2. 절차의 금지·중지 등의 효력과 그 기간

가. 강제집행 등 신청이 금지되는 절차가 새로이 신청된 경우에는 부적법하므로 각하하여야 한다. 이에 위반되어 개시된 절차는 그 본래의 효력을 발생시킬 수 없으므로 무효이다. 이미 행한 절차의 중지는 개시결정이 있으면 당연히 중지되는 것이고, 법원의 재판을 기다려 중지되는 것이 아니다. 여기서 ‘절차의 중지’란 진행되던 절차가 그 시점에서 동결되고 그 속행이 허용되지 아니함을 의미할 뿐 그 이상의 효력은 없다.

나. 회생절차의 개시는 집행장애사유에 해당하고 집행장애사유의 존재는 집행기관의 직권조사사항이므로,²⁴⁾ 집행기관은 채무자에게 회생절차 개시결정이 있는 사실을 발견한 때에는 개시결정 정보의 제출 등을 기다릴 필요 없이 직권으로 집행절차를 정지한 후 그 이후 집행행위를 하지 않고 현상을 유지한다(민집 제49조 제2호 참조).

다. 집행법원은 집행개시 전에 회생절차가 개시된 경우 집행을 신청을 각하하거

22) 대법원 2004. 4. 23. 선고 2003다6781 판결【판결요지】[1] 주식의 약식질권자인 원고가 주식의 소금대금채권에 대하여 물상대위권을 행사하기 위해서는 민법 제342조, 제355조, 구 민사소송법(2002. 1. 26. 법률 제6626호로 전문 개정되기 전의 것) 제733조 제2항, 제3항에 의하여 질권설정자가 지급받을 금전 기타 물건의 지급 또는 인도 전에 압류하여야 하나, 한편 회사정리법 제67조 제1항은 ‘정리절차개시의 결정이 있는 때에는 파산, 화의 개시 또는 정리절차개시의 신청과 정리채권 또는 정리담보권에 의한 회사재산에 대한 강제집행, 가압류, 가처분, 담보권 실행 등을 위한 경매를 할 수 없으며 파산절차 및 정리채권 또는 정리담보권에 의하여 회사재산에 대하여 이미 행한 강제집행, 가압류, 가처분, 담보권 실행 등을 위한 경매절차는 중지하고 화의절차는 그 효력을 잃는다.’고 규정하고 있고, 이와 같이 회사정리법 제67조 제1항에서 개별집행절차개시를 금지하는 규정을 둔 목적의 하나는 정리채권과 정리담보권 모두가 회사정리절차에 따라야 한다는 회사정리절차의 기본구조를 뒷받침하려는 데 있으므로 회사정리절차개시결정이 있는 후에는 물상대위권의 행사를 위한 압류의 허용 여부와는 별도로 추심명령은 그 효력을 발생시킬 수 없다. [2] 법원이 특정 정리채권(담보권)을 변제하지 아니하고서는 회사의 갱생에 현저한 지장을 초래할 우려가 있다고 인정하여 회사정리법 제112조의2 제2항에 따라 정리절차에 의하지 아니한 변제를 허가하였다 하더라도, 그 효과는 회사정리법 제112조에서 정한 정리채권 소멸금지의 효력이 해제됨에 그칠 뿐이고, 허가받은 내용대로 변제가 이루어지지 아니한 경우에 정리절차와 무관하게 개별적인 권리행사에 나아갈 수 있는 것은 아니다.

23) 서울중앙지방법원 파산부 실무연구회, 위 회생사건실무(상), 156.

24) 법원실무제요 민사집행(I), 법원행정처(2014), 267.

나 기각하여야 하고, 집행장애사유가 존재함에도 불구하고 이를 간과하고 집행절차를 개시한 후 이를 발견한 때에는 이미 행한 집행절차를 직권으로 취소하여야 한다.²⁵⁾ 집행정지사유가 있는데도 집행을 정지하지 아니하고 집행처분을 한 경우에는 이해관계인은 집행에 관한 이의신청, 즉시항고 또는 가압류나 가처분결정에 대한 이의신청을 하여 그 취소를 구할 수 있다.²⁶⁾

라. 회생계획 인가결정이 있으면 중지된 파산절차, 강제집행·가압류·가처분·담보권 실행 등을 위한 경매절차는 그 효력을 잃게 된다(채무자회생법 제256조 제1항). 다만 이때 효력을 잃은 파산절차에서의 재단채권(채무자회생법 제473조 제2호 및 제9호에 해당하는 조세 등의 청구권·부조료 등은 제외)은 공익채권으로 한다(채무자회생법 제256조 제2항).

마. 회생계획인가결정 전에 회생절차 폐지 또는 회생계획 불인가의 결정이 확정된 경우 중지된 절차가 당연히 속행된다. 그러나 만일 법원이 직권으로 파산을 선고한 경우(채무자회생법 제6조 제2항)에는 파산절차에서 파산채권에 기하여 파산재단에 속하는 재산에 대하여 한 강제집행 등은 그 효력을 잃게 되므로(채무자회생법 제348조 제1항), 중지 중인 절차가 파산절차에서 파산채권으로 보는 회생채권에 기하여 한 강제집행 등인 경우라면 당연 속행에 관한 규정은 의미가 없게 된다.

바. 신청금지의 효력이 지속되는 기간은 회생절차의 종료시까지이다(채무자회생법 제292조 제2항). 따라서 회생채권 등이 인가결정으로 권리변경이 확정된 후 채무자가 변제기에 이를 변제하지 않더라도 강제집행 등을 신청할 수 없다. 회생채권자 및 회생담보권자는 회생절차가 종결될 때까지 회생채권자표 또는 회생담보권자표에 의하여 강제집행을 할 수 없다(채무자회생법 제255조 제2항 참조).

3. 중지 중인 절차 · 처분의 속행, 취소

가. 중지 중인 절차의 속행

법원은 회생절차에 지장이 없다고 인정하는 때에는 중지한 절차 또는 처분의 속행을 명할 수 있다(채무자회생법 제58조 제5항).

25) 대법원 2000. 10. 2.자 2000마5221 결정

26) 법원실무제요 민사집행(I), 법원행정처(2014), 273. 다만 이러한 불복의 절차 없이 강제집행절차가 그대로 완결되면 그 집행행위에 의하여 발생한 법률효과를 부인할 수 없다(대법원 1992. 9. 14. 선고 92다28020 판결; 대법원 1993. 2. 16.자 94마1871 결정).

속행의 효과는 채납처분 등과 다른 절차의 경우가 서로 다르다. 즉 채납처분이 나 조세채무를 위한 담보물건의 처분을 속행하는 경우에는 목적재산을 환가하여 얻은 금전은 그대로 조세 등 청구권의 만족에 충당할 수 있다. 이에 대하여 일반의 회생채권, 회생담보권에 의한 강제집행이나 임의경매를 속행하는 경우에는 회생채권 등에 대한 회생절차에 의하지 아니한 변제가 금지되므로 이에 의하여 얻은 금전이 있더라도 법원의 허가를 받지 아니하는 한 그 채권에 충당할 수 없다(채무자회생법 제131조). 따라서 회생계획에서 그 회생채권, 회생담보권의 권리변경과 변제방법을 정할 때에 그 금전의 처리방법도 함께 정하게 된다.

중지중의 절차, 처분의 속행이 명하여진 경우에는 그 절차에 의하여 채무자에 대하여 발생한 비용청구권은 공익채권으로 된다(채무자회생법 제58조 제6항).

나. 중지 중인 절차처분의 취소

법원은 회생을 위하여 필요하다고 인정하는 때에는 관리인의 신청에 의하거나 직권으로 담보를 제공하게 하거나 제공하게 하지 아니하고 중지한 절차 또는 처분의 취소를 명할 수 있다(채무자회생법 제58조 제5항 후단). 여기에서 ‘회생을 위하여 필요하다고 인정하는 때’라 함은, 예컨대 회생계획인가 전에 그 절차 또는 처분의 대상이 된 재산(유휴부동산, 제품 등)을 관리인의 손으로 환가하여 운전자금으로 하거나 집행관이 점유하는 동산(원재료, 기계 등)을 사업의 계속을 위하여 회사에 가지고 올 필요가 있는 경우 등을 말한다.

법원은 취소를 명함에 있어서 관리인에게 담보를 제공하게 할 수 있다. 그 절차 처분이 회생계획인가에 의하지 않고 효력을 잃게 되므로 채권자가 손해를 입을 염려가 있다고 보아 담보제공을 명할 수 있도록 한 것이다. 취소명령이 되면 그 대상이 되었던 절차 또는 처분은 소급하여 효력을 잃는다. 압류 등의 효력도 소멸한다. 따라서 관리인은 자유로이 그 목적재산을 환가할 수 있다. 취소명령에 대하여는 불복신청이 인정되지 않으나(채무자회생법 제13조), 이를 인정할 필요가 있다.²⁷⁾

실무에서는 매출채권이나 원자재에 대한 가압류 등 강제집행과 채납처분 등에 대하여는 당해 매출채권이나 원자재 등을 이용할 수 없어 채무자의 정상적 운영에 방해가 된다고 보아 취소명령을 발하는 경우가 많다. 또한 부동산에 대한 가압류 등 강제집행은 그 부동산의 처분시 필요에 따라 취소하면 충분하므로 이를 처분하기 전에

27) 임채홍·백창훈, 회사정리법(상), 한국사법행정학회(2002), 221. ; 三ヶ月章 外 5人, 條解 會社更生法(下), 弘文堂(1999), 593.

는 관리인으로 하여금 취소명령신청을 하지 않도록 유도하고 있다.

IV. 회생계획인가결정과 강제집행

1. 채무자의 재건계획을 문서화한 회생계획안은 법원의 인가결정을 받음으로써 회생계획으로서 그 효력이 발생한다(채무자회생법 제246조). 회생계획인가결정이 있는 때에는 회생계획의 규정 또는 채무자회생법의 규정에 의하여 인정된 권리를 제외하고 채무자는 모든 회생채권과 회생담보권에 관하여 그 책임을 면하며, 주주·지분권자의 권리와 채무자의 재산상에 있던 모든 담보권은 소멸하고(채무자회생법 제251조), 회생채권자·회생담보권자의 권리는 회생계획에 따라 변경된다(채무자회생법 제252조 제1항).²⁸⁾ 따라서 회생채권에 관하여 회생절차개시 이전부터 회생채권 또는 회생담보권에 관하여 집행권원이 있었다 하더라도, 회생계획인가결정이 있는 후에는 채무자회생법 제252조에 의하여 모든 권리가 변경·확정되고 종전의 회생채권 또는 회생담보권에 관한 집행권원에 의하여 강제집행 등은 할 수 없으며, 회생채권자표와 회생담보권자표의 기재만이 집행권원이 된다.²⁹⁾

2. 회생계획인가결정이 있으면 채무자회생법 제58조 제2항에 의하여 중지된 강제집행, 가압류, 가처분, 담보권 실행 등을 위한 경매절차는 그 효력을 잃는다(채무자회생법 제256조 제1항 본문).³⁰⁾ 다만 법원의 명령에 의하여 그 중지된 절차가 속행된 경우에는 그러하지 아니하다(채무자회생법 제256조 제1항 단서).

3. 회생계획 인가결정 전에 회생절차가 종료되는 경우에는 중지 중인 절차가 당연히 속행된다[다만 회생계획인가 전 회생절차폐지 또는 회생계획불인가의 결정이 확정된 경우 법원은 신청 또는 직권으로 파산을 선고할 수 있고(채무자회생법 제6조 제2항), 그럴 경우 파산절차에서 파산채권에 관하여 파산재단에 속하는 재산에 대하여 한 강제집행, 가압류, 가처분은 그 효력을 잃게 된다(채무자회생법 제348조 제1항)].

28) 여기서 말하는 면책이란 채무 자체는 존속하지만 채무자에 대하여 이행을 강제할 수 없다는 의미이고, 권리변경이란 채무와 구별되는 책임만이 변경되는 것이 아니라 회생계획의 내용대로 권리가 실체적으로 변경된다는 의미이다(대법원 2018. 11. 29. 선고 2017다286577 판결).

29) 대법원 2017. 5. 23.자 2016마256 결정

30) 구 화의법상 채권자가 화의채권에 관한 확정판결에 기하여 화의인가결정 확정 후 한 강제집행은 구 화의법 제40조 제1항에 의하여 무효라는 것에는, 대법원 2006. 4. 17.자 2004마960 결정이 있다.

따라서 중지 중인 절차가 파산채권이 되는 회생채권에 기한 강제집행, 가압류, 가처분인 경우라면 위 속행에 관한 규정이 무의미하게 될 수도 있다].

V. 회생절차의 종료와 강제집행

회생절차의 종료라 함은 일단 개시된 회생절차가 그 목적을 달성하거나 달성하지 못하는 등의 사유로 회생절차에서 벗어나게 되는 것을 말한다.

회생절차 종료의 사유로는 회생절차의 종결(채무자회생법 제283조), 회생계획인가 전의 폐지(채무자회생법 제286조), 신청에 의한 폐지(채무자회생법 제287조), 회생계획인가 후의 폐지(채무자회생법 제288조), 회생계획의 불인가(채무자회생법 제242조, 제248조) 및 항고심에서의 회생계획 인가결정에 대한 취소(채무자회생법 제247조), 회생절차 개시결정의 취소(채무자회생법 제54조) 등이 있다.

1. 회생절차 종결의 경우

회생절차의 종결은 법원이 회생계획이 수행된 때 또는 회생계획의 수행이 확실하여 회생절차의 목적을 달할 수 있는 경우에 ‘관리인’이나 ‘목록에 기재되어 있거나 신고한 회생채권자 또는 회생담보권자’의 신청에 의하거나 직권으로 회생절차를 종료시키는 것을 말한다(채무자회생법 제283조). 회생절차 종결의 요건으로 ① 회생계획에 따른 변제가 시작된 이후이어야 하고, ② 회생계획의 수행에 지장이 없다고 인정되어야 한다.

회생절차가 종결되면 개별적 권리행사의 제약이 해소되므로 회생채권자 등은 채무자회생법 제255조 제2항에 따라 회생채권자표 등에 기하여 채무자, 신 채무자 및 회생을 위하여 채무를 부담하거나 또는 담보를 제공한 자에 대하여 강제집행을 할 수 있다.

2. 회생절차 폐지의 경우

가. 의의

회생절차의 폐지라 함은 회생절차 개시 후에 당해 회생절차가 그 목적을 달성하지 못하는 법원이 그 절차를 단절시키는 것을 말한다(채무자회생법 제286조부터 제288조까지).

회생절차가 폐지되면 개별적 권리행사가 가능하게 된다. 회생절차 개시결정으로

인하여 채무자회생법 제58조 제1항, 제2항에 의하여 중지된 경매절차, 체납처분 등 절차는 폐지결정으로 중지가 해소되고 절차는 속행된다. 다만 이는 회생계획인가 전에 한하고 회생계획인가 후에는 원칙적으로 그러한 절차가 실효되므로 속행의 문제가 생기지 아니한다.

나. 회생계획인가 전의 폐지

1) 의의

① 법원은 법원이 정한 기간 또는 연장한 기간 안에 회생계획안의 제출이 없거나 그 기간 안에 제출된 모든 회생계획안이 관계인집회의 심리 또는 결의에 부칠 만한 것이 못되는 때,³¹⁾ ② 회생계획안이 부결되거나 결의를 위한 관계인집회의 제1기일부터 2월 이내 또는 연장한 기간 안에 가결되지 아니하는 때,³²⁾ ③ 회생계획안이 채무자회생법 제239조 제3항의 규정에 의한 기간 안에 가결되지 아니한 때, ④ 채무자회생법 제240조 제1항의 규정에 의한 서면결의에 부치는 결정이 있을 때에 그 서면결의에 의하여 회생계획안이 가결되지 아니한 때(다만 서면결의에서 가결되지 아니한 회생계획안에 대하여 채무자회생법 제238조의 규정에 의한 속행기일이 지정된 때에는 그 속행기일에서 가결되지 아니한 때를 말한다)에는 직권으로 회생절차폐지의 결정을 하여야 한다(채무자회생법 제286조 제1항). 이를 회생계획인가 전의 폐지라 한다.

2) 확정된 회생채권 또는 회생담보권의 경우

회생절차에 있어서 권리의 존재가 확정된 회생채권 또는 회생담보권에 관하여는 이러한 회생계획인가 전에 절차가 폐지된 경우라도 채무자에 대한 관계에서는 그 효력을 인정할 것이 요망된다. 따라서 법은 회생계획 인가결정 전에 회생절차가 폐지된 경우에는 확정된 회생채권 또는 회생담보권에 관하여는 회생채권자표 또는 회생담보권자표의 기재는 채무자가 조사기일에 있어서 그 권리에 대하여 이의를 하지 아니한 경우에 한하여 채무자에 대하여 확정판결과 동일한 효력이 있도록 하였다(채무자회생법 제292조 제1항). 이의를 제기하지 않은 것은 상대방의 권리를 승인한 것으로 볼

31) '심리 또는 결의에 부칠 만한 것이 못되는 때'란 계획안의 내용이 법률의 규정에 반하는 경우이거나 공정, 형평하지 아니하여 수행이 불가능하다고 인정되어 계획안을 배제해야 할 경우를 말한다(대법원 1982. 9. 30. 자 82마585 결정). 이 경우에는 회생계획안의 배제결정과 회생절차의 폐지결정을 동시에 하여야 한다.

32) 회생계획안의 가결기간은 회생절차를 신속하게 진행하여 그 지연을 막고자 결의를 위한 관계인집회의 제1기일로부터 2개월 내에 그리고 회생절차 개시일로부터 1년 내에 가결하여야 한다. 법원이 이 가결기간을 연장한 경우에는 그 연장된 기간 내에 가결되어야 하지만, 그 기간 내에 회생계획안이 가결되지 아니한 경우에는 반드시 회생절차를 폐지하여야 한다.

수 있기 때문이다. 이의를 하지 않았다고 함은 조사기일에 관리인 등이 출석하여 이의를 하지 않은 경우뿐만 아니라 출석 자체를 하지 않은 경우도 포함된다.

여기서의 ‘확정판결과 동일한 효력’에 기판력도 포함되는가가 문제된다. 채무자회생법 제168조나 제255조의 ‘확정판결과 동일한 효력’과 마찬가지로 채무자회생법 제292조의 경우에도 기판력은 발생하지 않고 집행력만 생긴다고 보는 것이 타당하다.³³⁾ 기판력이 발생하지 않으므로 채무자는 회생채권자표와 회생담보권자표 기재의 채권에 관하여 그 작성 전의 사유로 부존재를 주장할 수 있다. 다만 회생채권자표와 회생담보권자표의 기재가 확정판결과 동일한 효력이 있는 결과 민법의 시효기간을 적용함에 있어서는 민법 제165조가 적용된다. 따라서 채무자에 대하여 확정판결과 동일한 효력이 있는 회생채권 등에 관하여는 그 시효기간이 10년보다 짧은 경우에도 10년으로 신장(伸長)된다.

3) 회생채권자표 또는 회생담보권자표의 집행력

회생채권자 또는 회생담보권자는 회생절차 종료 후 채무자에 대하여 회생채권자표 또는 회생담보권자표에 의하여 강제집행을 할 수 있다(채무자회생법 제292조 제2항). 이는 회생채권자표와 회생담보권자표의 집행력을 규정한 것이다. 여기서 강제집행을 할 수 있는 자는 확정된 회생채권자 또는 회생담보권자를 말한다. 조사절차에서 확정하든 확정소송에서 확정하든 상관없다. 회생채권자표 또는 회생담보권자표에 기하여 채무자에 대하여 하는 강제집행에 관하여는 원칙적으로 판결에 기한 강제집행에 관한 민사집행법 제28조 내지 제55조의 규정이 준용된다(채무자회생법 제292조 제3항, 제255조 제3항).

집행은 집행문을 부여받은 회생채권자표, 회생담보권자표의 정본에 기하여 한다. 집행문은 회생법원의 서기관 또는 서기가 부여한다. 회생채권자표, 회생담보권자표에 기한 강제집행에 관하여 제기되는 집행문부여의 소, 청구이의의 소, 집행문부여에 대한 이의의 소는 회생법원의 전속관할에 속한다(채무자회생법 제292조 제3항, 제255조 제3항).

4) 청구이의의 소 등

청구이의의 소와 관련하여, 회생채권자표, 회생담보권자표의 기재는 기판력이 없으므로 민사집행법 제44조 2항은 준용되지 않고 채무자는 회생채권, 회생담보권에 관한 기재가 실체상의 권리상태와 다른 때에는 청구이의의 소를 제기하여 조사기일 이전의 사유로 회생채권, 회생담보권의 부존재를 주장할 수 있다.

33) 三ヶ月章 外 5人(주430), 1851.

회생채권자표 또는 회생담보권자표의 기재에 명백한 오류가 있을 때에는 민사소송법 제211조를 유추하여 경정결정의 신청을 할 수 있다. 그리고 위 표의 기재는 기판력이 없으므로 재심의 소는 허용되지 않는다.

다. 회생계획인가 후의 폐지

회생계획인가의 결정이 있은 후 회생계획을 수행할 수 없는 것이 명백하게 된 때³⁴⁾에는 법원은 관리인이나 목록에 기재되어 있거나 신고한 회생채권자 또는 회생담보권자의 신청에 의하거나 직권으로 회생절차폐지의 결정을 하여야 한다(채무자회생법 제288조 제1항). 폐지는 결정으로 하며 이러한 폐지결정은 즉시항고되는 경우가 많기 때문에 법원은 상급심의 판단에 도움을 준다는 차원에서 폐지결정의 이유에는 회생계획의 수행가능성이 없음이 명백한 이유를 기재하는 것이 바람직하다.

회생계획인가 후에 회생절차가 채무자회생법 제288조에 따라 폐지된 경우에는 회생채권자, 회생담보권자는 회생계획에 의하여 인정된 금전의 지급 기타 이행청구권에 관하여는 그 기재가 있는 회생채권자표, 회생담보권자표에 기하여 채무자 및 회생을 위하여 채무를 부담한 자에 대하여 강제집행을 할 수 있다. 집행을 할 수 있는 시기는 폐지결정이 확정된 이후이다. 집행문도 이때에 비로소 부여받을 수 있다. 위의 강제집행에 관하여는 민사집행법 제28조 내지 제55조가 준용된다(채무자회생법 제293조, 제255조 제3항). 다만 집행문부여의 소와 청구이의의 소, 집행문부여에 대한 이의의 소는 회생법원의 전속관할로 한다.

3. 회생계획 불인가의 경우

회생계획 불인가결정이 확정되면 역시 개별적 권리행사가 가능하게 된다. 다만 회생절차는 적법하게 개시되고 수행된 것이므로 회생절차 개시결정의 취소와는 달리 회생절차 중의 법률효과는 원칙적으로 소급하여 무효로 되지는 않는다. 이 점에서 회생계획 인가결정 전의 회생절차폐지의 경우와 비슷하다고 할 수 있다.

따라서 회생절차 중 확정된 회생채권, 회생담보권 중 조사기일에 채무자가 이의하지 않은 것에 관한 회생채권자표, 회생담보권자표에의 기재는 채무자에 대하여 확정판결과 동일한 효력이 있고 회생채권자, 회생담보권자는 이에 의하여 채무자에 대

34) 회생계획의 수행할 가능성이 없다는 것은 회생절차 기간 중에 다시 도산할 우려가 높은 경우이거나 회생절차 기간이 종료된 경우라도 독립하여 사업을 영위할 수 있는 여력이 없다는 것을 의미한다.

하여 강제집행을 할 수 있다(채무자회생법 제248조, 제292조). 항고심에서 회생계획인가결정을 취소되면 회생계획은 소급적으로 그 효력을 상실하고 회생절차가 종료하므로, 회생계획 불인가결정의 경우와 마찬가지로 볼 수 있다.

4. 회생절차 개시결정 취소의 경우

회생절차 개시의 취소결정이 확정되면 그 개시결정은 소급적으로 그 효력을 상실하고, 그때까지 채무자에 대하여 할 수 없었던 구 채권에 기한 소송의 제기, 채무자재산에 대한 강제집행, 가압류, 가처분, 경매절차, 체납처분절차를 자유로이 할 수 있다.

회생절차 개시결정에 의하여 중지된 강제집행, 가압류·가처분, 경매법원에 의한 경매절차 및 체납처분은 중지상태가 끝나고 당연히 속행된다. 회생절차 개시결정에 의하여 중지된 파산절차는 취소결정의 확정으로 당연히 원래의 파산법원에 의하여 속행되고(채무자회생법 제6조), 또 회생절차의 필연적 일환으로 행하여진 행위의 효과는 취소결정의 확정으로 소멸하므로, 조사기일에서 이미 없이 확정된 채권자표에 기재됨에 따라 생기는 확정판결과 동일한 효력은 소멸한다. 이 점에서 회생절차의 폐지나 회생계획의 불인가의 경우 회생채권자표 등의 기재의 효력이 지속되는 것과 다르다. 그리고 부인권은 회생절차 중에만 인정되는 권리로서 취소결정에 의하여 소멸하므로, 이미 부인의 소송에 관한 판결이 확정되거나 강제집행이 끝난 후에도 그 효력은 부인되어야 한다.

VI. 개인회생절차와 채권압류

1. 개인회생절차의 의의 등

개인회생이란, 파산의 원인인 사실이 있거나 그러한 사실이 생길 염려가 있는 자로서 총 채무액이 무담보채무의 경우에는 5억 원, 담보부채무의 경우에는 10억 원 이하³⁵⁾인 급여소득자 또는 영업소득자가, 원칙적으로 5년간 일정한 금액을 변제하면 잔액의 면제를 받을 수 있는 절차이다.

개인회생사건의 절차는, ① 신청서의 제출, ② 신청서에 대한 법원의 심리, ③

35) 따라서 예컨대 담보부채무가 8억 원, 무담보채무가 4억 원 합계 12억 원의 채무를 지고 있는 채무자는 개인회생절차를 신청할 수 있지만, 담보부 채무는 없고 무담보채무를 6억 원 지고 있는 채무자는 이 절차를 신청할 수 없다. 부채액 한도의 기준시점은 개인회생절차의 개시결정일이다.

변제계획안의 제출 및 변제의 개시, ④ 회생위원의 선임, ⑤ 법원의 개시결정, ⑥ 개인회생채권자의 이의, ⑦ 변제계획안의 수정 및 확정, ⑧ 개인회생채권자집회, ⑨ 변제계획안의 인가, ⑩ 절차의 수행과 면책 등으로 진행된다.

2. 개인회생채권자목록

가. 제출의 효과

개인회생채권자목록은 채무자회생법 제589조 제2항 제1호에 따라 개인회생절차 개시신청서에 반드시 첨부되어야 할 문서 중의 하나로서, 채무자가 부담하고 있는 개인회생채권의 내용, 규모를 파악하여 변제계획 작성의 기초를 마련하는 것을 1차적인 목표로 하고 있다(채무자회생법 제611조).

개인회생채권자목록은 개시신청에서부터 면책 여부의 결정에 이르기까지 개인회생절차의 각 단계에서 목록의 제출 여부나 개별 개인회생채권자의 채권의 기재 여부, 개인회생채권액의 합계 여하 등에 일정한 법적 효과가 부여되어 있다. 즉 개인회생채권자목록의 제출에는 시효중단의 효력이 있고(채무자회생법 제32조 제3호), 그 목록에 기재된 채권은 변제계획에 의하지 아니하고는 이를 소멸하게 하는 행위를 하지 못하며(채무자회생법 제582조), 위 목록이 제출되지 아니한 것은 개인회생절차개시신청의 기각사유가 되고(채무자회생법 제595조 제2호), 개인회생절차의 개시로 인하여 개별적 집행이 중지되는 채권은 개인회생채권자목록에 기재된 채권에 한하며(채무자회생법 제600조 단서), 개인회생채권자목록에 기재된 채권에 대하여 이의기간 내에 개인회생채권조사확정재판이 신청되지 않은 경우, 해당 채권은 채권자목록에 기재된 바와 같이 확정되고(채무자회생법 제603조 제1항 제1호), 면책결정 당시까지 채무자에 의하여 악의로 개인회생채권자목록에 기재되지 아니한 개인회생채권이 있는 경우에는 법원은 면책불허가결정을 할 수 있으며(채무자회생법 제624조 제3항 제1호), 면책결정이 확정되는 경우에도 개인회생채권자목록에 기재되지 아니한 개인회생채권에 관하여는 면책의 효력이 인정되지 아니한다(채무자회생법 제625조).³⁶⁾

나. 당사자의 채권과 채권자목록상 개인회생채권의 동일성 판단

강제집행 등 또는 본안소송에서 채권자의 채권이 개인회생절차에서의 채권에 해당하는지를 선행적으로 판단하여야 한다. 개인회생절차와의 관련성이 문제되는 경우,

36) 서울중앙지방법원 파산부 실무연구회, 개인파산·회생실무, 박영사(2012), 274-275.

입증당사자에게 채권자목록을 제출케 하여, 당사자의 채권과 채권자목록상의 채권의 동일성을 확인하여야 하고, 그 확인시에는 개인회생채권자목록에 기재된 채권의 발생 당시를 기준으로 한 차용금, 매매대금 등의 채권의 발생원인, 시기 또는 기간 등을 참고하여야 할 것이다.

한편 채무자가 채권의 원인 및 내용을 개략적으로만 기재하여 채권자목록의 기재만으로는 당사자의 채권과의 동일성을 확인할 수 없는 경우에는 채무자로 하여금 개인회생법원에서 부채확인서, 차용증 등 채무소명자료의 사본을 교부받아 제출하거나 채권자로부터 동일성 확인에 필요한 사항이 기재되어 있는 부채확인서를 교부받아 제출하도록 하여 그 소명자료에 기재되어 있는 내용 등을 참고하여야 할 것이다.³⁷⁾

3. 집행절차에 미치는 영향

가. 개인회생절차개시신청 단계

1) 서

법원은 개인회생절차개시의 신청일부터 1월 이내에 개인회생절차의 개시 여부를 결정하도록 되어 있으나(채무자회생법 제596조 제1항), 채무자가 개인회생절차 개시 신청을 한 경우 그 신청 자체만으로는 아무런 법률적 효력이 없다. 신청과 동시에 개인회생채권자목록을 제출함으로써 시효가 중단되는 효과가 있을 뿐이다.

따라서 개시 여부를 심리하고 있는 단계에서 채무자가 채권의 담보이자 회생의 기초인 재산을 은닉 또는 처분하거나 이해관계인에 의한 권리행사가 쇄도하는 등 혼란과 이해관계인간의 불공평이 발생하여 영업의 계속이 곤란하게 되고 회생의 목적을 달성할 수 없는 사태가 발생할 수 있다. 이를 방지하고 개인회생절차 개시신청부터 개시결정에 따른 중지, 금지의 효력이 발생할 때까지의 공백을 메우기 위하여 채무자는 개인회생절차 개시신청과 동시에 중지, 금지명령 신청을 할 수 있도록 하고 있다.

2) 중지·금지명령

가) 의의 : 개인회생절차개시의 신청이 있는 경우에 필요하다고 인정하는 때에는 법원은 이해관계인의 신청에 의하여 또는 직권으로 개인회생절차개시의 신청에 대한 결정시까지 개인회생채권에 기하여 채무자의 업무 및 재산에 대하여 한 강제집행 등의 중지 또는 금지를 명할 수 있다(채무자회생법 제593조 제1항). 그 성질, 집행방법

37) 황진희, “개인파산, 개인회생절차가 집행절차 및 소송절차에 미치는 영향”, 재판실무연구(2011), 광주지방법원, 42.

등은 개인파산절차에서 면제재산에 관한 중지·금지명령과 동일하다.

나) 중지·금지명령의 대상이 되는 절차 : 개인회생절차의 특성상 주로 중지·금지명령의 대상이 되는 절차는 채무자의 장래 급여채권에 대한 채권압류·추심·전부명령이다. 그런데 중지·금지명령이 있기 전에 채무자의 장래 급여채권에 대하여 이미 유효한 전부명령이 발하여져 확정된 경우에는 그 전부채권자가 채무자의 장래 급여채권을 이전받음으로 인하여 개인회생절차의 진행에 곤란을 초래할 수 있다. 이러한 문제점을 해결하기 위하여 채무자회생법 제616조는 전부명령에 대한 특칙을 규정하고 있다(이에 대하여는 변제계획 인가결정 부분 참조).

개인회생절차가 있어도 담보권자의 권리행사는 제약을 받지 않는 것이 원칙이다.³⁸⁾

다) 효력의 존속기간 : 중지·금지명령이 효력을 가지는 것은 개인회생절차에서의 신청에 관한 결정이 있을 때까지이다. 개인회생절차개시결정이 있으면 강제집행 등의 절차는 당연히 중지 또는 금지되고, 그 개인회생절차개시의 신청이 기각되면 중지·금지명령은 당연히 실효되어 중지된 절차는 다시 진행을 할 수 있게 된다(채무자회생법 제593조 제2항). 이를 저지하기 위해서는 신청을 기각하는 결정에 대하여 즉시항고를 하고 항고심에서 다시 중지·금지명령을 얻어야 한다(채무자회생법 제598조 제2항). 개인회생절차개시신청의 취하에 대하여 법원의 허가가 있는 경우에도 중지·금지명령은 실효된다.

라) 소급효 부정 : 중지명령이 있어도 당해 절차에 관하여 그때까지 행하여진 행위를 소급적으로 무효로 하는 것은 아니므로 회생절차 참가, 파산절차 참가, 강제집행, 경매 등에 의하여 이미 발생한 시효중단의 효력은 중지명령 후에도 계속된다. 강제집행 등에 의한 시효중단의 효력이 발생하기 전에 금지를 내용으로 하는 금지명령이 발하여진 경우 시효중단의 효력이 있다고 볼 것인가가 문제되나, 채무자회생법 제600조 제4항을 유추적용하여 금지된 기간 중에는 시효가 진행되지 않는 것으로 봄이 타당하다.³⁹⁾

3) 포괄적 금지명령

회생절차편의 포괄적 금지명령에 관한 규정인 채무자회생법 제45조 내지 제47조

38) 그러나 담보권의 실행에 의하여 생활의 기반이 되는 자산이나 영업의 계속에 필수적인 자산이 환가(현금화)된다면 개인회생절차의 진행에 지장이 초래되고, 채무자의 회생이 곤란하게 될 수도 있으므로, 법원은 채무자의 업무 및 재산에 대한 담보권설정 또는 담보권 실행 등을 위한 경매절차도 중지 또는 금지할 수 있다(채무자회생법 제593조 제1항).

39) 서울중앙지방법원, 위 개인파산·회생실무, 308.

는 개인회생절차에도 준용된다(채무자회생법 제593조 제5항).

따라서 법원은 개인회생절차개시의 신청이 있는 경우 채무자회생법 제593조 제1항의 규정에 의한 중지·금지명령에 의하여는 개인회생절차의 목적을 충분히 달성하지 못할 우려가 있다고 인정할 만한 특별한 사정이 있는 때에는 이해관계인의 신청에 의하거나 직권으로 개인회생절차개시의 신청에 대한 결정이 있을 때까지 모든 개인회생채권자 및 개인회생담보권자에 대하여 개인회생채권 또는 개인회생담보권에 기한 강제집행 등의 금지를 명할 수 있다(채무자회생법 제593조 제5항, 제45조 제2항). 또 팔적 금지명령이 있으면 채무자의 재산에 대하여 이미 행하여진 개인회생채권에 기한 강제집행 등은 중지된다(채무자회생법 제593조 제5항, 제45조 제3항).

나. 개인회생개시결정이 있는 경우

1) 중지·금지

개인회생절차개시결정이 있는 때에는 개인회생채권자목록에 기재된 개인회생채권에 기하여 개인회생재단에 속하는 재산에 대하여 이미 계속 중인 강제집행 등은 중지되고, 새로이 강제집행 등을 하는 것은 금지된다(채무자회생법 제600조 제1항 제2호). 중지·금지되는 절차는 개인회생채권, 즉 채무자에 대하여 개인회생절차개시결정전의 원인으로 생긴 재산상의 청구권(채무자회생법 제581조 제1항)에 기한 것에 한하므로 개인회생채권이 아닌 개인회생재단채권(채무자회생법 제583조), 환취권(채무자회생법 제585조)⁴⁰⁾에 기한 강제집행, 가압류 또는 가처분은 허용된다.

또한 ‘개인회생재단에 속하는 재산’에 대하여 행하는 강제집행 등에 한하여 중지·금지되므로 연대채무자, 보증인, 물상보증인 등 제3자의 재산에 대하여 행하는 것은 중지·금지되지 않는다.

개인회생절차개시의 결정이 있는 때에는 개인회생재단에 속하는 재산에 대한 담보권의 설정 또는 담보권의 실행 등을 위한 경매는 중지 또는 금지된다(채무자회생법 제600조 제2항). 담보권의 실행으로 채무자의 영업이나 생계를 위하여 필수적인 재

40) 관련판례 : 대법원 2014. 4. 10. 선고 2013다61190 판결 【판결요지】동산의 소유권유보부매매는 동산을 매매하여 인도하면서 대금 완납 시까지 동산의 소유권을 매도인에게 유보하기로 특약한 것을 말하며, 이러한 내용의 계약은 동산의 매도인이 매매대금을 다 수령할 때까지 대금채권에 대한 담보의 효과를 취득·유지하려는 의도에서 비롯된 것이다. 따라서 동산의 소유권유보부매매의 경우에, 매도인이 유보한 소유권은 담보권의 실질을 가지고 있으므로 담보 목적의 양도와 마찬가지로 매수인에 대한 회생절차에서 회생담보권으로 취급함이 타당하고, 매도인은 매매목적물인 동산에 대하여 환취권을 행사할 수 없다.

산이 상실될 수 있으므로, 적어도 개인회생절차 진행 중에는 이를 중지시키겠다는 것이 입법취지이다.

2) 취소명령

법원은 상당한 이유가 있는 때에는 이해관계인의 신청에 의하거나 직권으로 채무자회생법 제600조 제1항 또는 제2항의 규정에 의하여 중지된 절차 또는 처분의 속행 또는 취소를 명할 수 있다. 다만 처분의 취소의 경우에는 담보를 제공하게 할 수 있다(채무자회생법 제600조 제3항).

채무자회생법 제600조 제1항 또는 제2항의 규정에 의하여 처분을 할 수 없거나 중지된 기간 중에는 시효가 진행되지 아니한다.

다. 변제계획인가결정이 있는 경우

1) 중지된 강제집행 등의 효력 상실

변제계획인가결정이 있으면 비로소 중지된 강제집행 등은 그 효력을 상실하게 된다(채무자회생법 제615조 제3항). 변제계획불인가결정 및 폐지결정이 있는 때에는 그 중지된 강제집행 등을 속행할 수 있다.

절차가 효력을 잃는다는 것은 앞으로의 속행을 허용하지 않는다는 뜻이 아니라 소급하여 그 절차가 효력을 잃는다는 것을 의미한다. 따라서 법원의 재판 없이도 그 효력을 잃는다. 다만 강제집행 등은 이미 진행되어 있는 절차의 외형을 제거하기 위한 형식적인 절차가 필요하다. 그러나 이러한 절차에 관하여 법률이 별도의 규정을 두고 있지 않고, 회생법원으로서 어느 재산에 관하여 어느 법원에서 어떤 절차가 진행되고 있는지 직접 확인하기가 곤란하며, 그 절차의 기록도 보관하고 있지 않으므로, 결국 채무자가 해당 집행법원에 말소등기촉탁신청서와 함께 인가결정등본 및 말소촉탁의 대상이 되는 재산의 목록을 첨부하여 신청하여야 한다.⁴¹⁾

2) 급여채권 등에 관하여 절차개시 전 확정된 전부명령의 효력

변제계획인가결정이 있는 때에는 채무자의 급료·연금·봉급·상여금, 그 밖에 이와 비슷한 성질을 가진 급여채권에 관하여 개인회생절차개시 전에 확정된 전부명령은 변제계획인가결정 후에 제공한 노무로 인한 부분에 대하여는 그 효력이 상실되고(채무자회생법 제616조 제1항), 변제계획인가결정으로 인하여 전부채권자가 변제받지 못하게 되는 채권액은 개인회생채권으로 된다(같은 조 제2항).

41) 서울중앙지방법원, 위 개인파산·회생실무, 460.

3) 중지된 강제집행 등의 효력이 존속하게 되는 경우

채무자회생법 제600조의 규정에 의하여 중지된 강제집행 등의 효력이 존속한다는 내용으로 변제계획 또는 변제계획인가결정에서 다르게 정할 수 있다(채무자회생법 제615조 제3항 단서). 변제계획에 다르게 정할 경우로는 ① 채무자가 당해 가압류, 가처분이 이루어진 재산을 변제에 제공하지 않는 내용의 변제계획안을 제출하고 있고, ② 채무자의 성실성이 의심되는 전후 사정에 비추어 강제집행 등이 실효된다면 채무자가 향후 이를 임의처분한 후 변제계획까지 이행하지 아니함으로써 개인회생채권자들에게 손해를 입힐 우려가 있는 경우 등을 들 수 있다.⁴²⁾ 따라서 채무자가 “변제계획 인가결정을 이유로” 강제집행 등의 해제를 구하여 오면, “변제계획 인가결정의 주문 또는 변제계획안의 기타 사항”에 강제집행 등의 효력을 다르게 정함이 있는지 여부에 주의를 기울여야 한다.

42) 이 경우 변제계획에서는 당해 재산의 강제집행 등을 변제계획 기간 중의 일정시점이나 혹은 변제계획 기간 종료시까지 계속 중지, 존속시키거나 혹은 속행한다는 내용의 규정을 두게 될 것이다.

제2절 채권압류와 파산

I. 서설

파산절차란, 채무자에게 파산의 원인이 있을 때 파산선고를 하고 채권조사절차를 통하여 채권자의 권리를 확정된 다음, 채무자의 재산을 환가(현금화)하여 권리의 우선순위와 채권액에 따라 환가(현금화)된 금원을 분배하는 과정을 말한다.⁴³⁾ 이는 파산선고에 의하여 개시되고 원칙적으로 종결결정에 의하여 종료된다.

법원은 채권자 또는 채무자의 신청이 있으면⁴⁴⁾ 필요한 증거조사를 거쳐 신청인의 자격, 파산원인의 존부를 심리한 후 채무자가 지급불능 또는 채무초과의 상태에 있다고 인정될 경우 파산선고를 하게 된다.

그런데 채무자에 대한 이와 같은 파산선고가 그 채무자에 대해 채권압류명령이 발령된 후에 된 경우가 있고, 또한 실체는 채권압류명령 발령 전에 파산선고가 있었으나 그 사실이 채권압류명령 후에야 판명된 경우도 있는바, 이와 같은 경우 집행절차에 대한 취급에 대하여 여러 가지 문제점이 생각되어질 수 있다. 즉 이 경우에 이미 행한 집행절차의 효력은 어떻게 되는가, 진행 중인 집행절차는 어떻게 해야 하는가, 공탁된 금원은 누가 어떻게 지급받을 수 있는가 등의 문제가 발생하게 되는 것이다.

II. 파산선고의 효과

1. 파산자의 재산관계에 대한 효과

가. 파산재단의 성립

파산선고에 의하여 파산자가 파산선고시에 가진 모든 재산은 파산재단을 구성한다[채무자 회생 및 파산에 관한 법률(이하 ‘채무자회생법’이라고 한다) 제382조 제1항]. 그리고 이후의 파산절차는 파산재단에 속하는 재산을 대상으로 이루어진

43) 서울지방법원실무연구회, 파산사건실무(개정판), 한양당(2001), 1.

44) 직권으로 파산선고를 하는 경우도 있다.

다.⁴⁵⁾ 여기서 파산재단에 속하는 재산이란 파산선고시에 파산자에 속한 적극재산으로서 압류가 가능한 것을 말한다.

압류금지재산, 파산자가 파산선고 후에 새로이 취득한 재산[이른바, 신득재산(新得財産)]은 파산재단에 속하지 않는 재산으로서 자유재산이라고 한다. 법인의 경우에 자유재산의 개념을 인정할 수 있는가에 관하여는 현재 다툼이 있는 것으로 보인다.⁴⁶⁾

나. 관리처분권의 이전

파산선고에 의하여 파산자는 파산재단을 구성하는 재산에 관한 관리처분권을 잃고, 이 관리처분권은 파산관재인에게 전속하게 된다(채무자회생법 제384조). 따라서 파산선고 후 파산자가 재단 소속 재산에 관하여 한 법률행위를 가지고 파산채권자에 대항할 수 없다(채무자회생법 제329조).

파산관재인은 파산선고 후 즉시 파산재단의 점유관리에 착수하고, 재단에 관한 소송에 관하여는 당사자로서 소송행위를 한다(채무자회생법 제359조). 그러나 재단 소속 재산의 소유권은 여전히 파산자에게 있고, 파산자는 자유재산에 대한 관리처분권을 그대로 보유할 수 있을 뿐 아니라 파산절차에 관한 재판에 대하여 즉시항고를 할 수도 있으며, 재단에 관한 소송 이외의 소송(예컨대, 파산자 주주총회결의 무효의 소)에 관하여는 당사자로서의 지위를 잃지 않는다.

다. 계속 중인 소송·강제집행·가압류·가처분 등에 대한 효과⁴⁸⁾

1) 계속 중인 소송에 대한 효과

가) 파산선고로 인하여 파산재단의 관리처분권이 파산관재인에게 이전되는 결과,

45) 이와 같이 파산선고시에 파산재단의 범위를 확정하는 입법방식을 「고정주의」라고 하고, 이에 대하여 파산선고 후에도 재산을 순차 파산재단에 편입시키는 방식을 「팽창주의」라고 한다. 고정주의는 선고시 책임재산의 범위를 고정하므로 파산관재인이 신속하고 확립적으로 재산을 관리처분할 수 있고, 선고 후에 채무자가 취득한 재산은 자유재산으로 되어 선고 후에 생긴 신 채권자에의 변제재원이 되므로 신, 구 채권자를 공평하게 보호할 수 있을 뿐 아니라, 채무자는 자유재산을 사업활동에 사용할 수 있어 재기의 기회를 얻을 수 있다는 장점이 있다[서울지방법원실무연구회(주1), 43, 참조].

46) 서울지방법원실무연구회(주1), 43.

47) 한편, 신탁재산은 수탁자의 고유재산이 된 것을 제외하고는 수탁자의 파산재단을 구성하지 않는다(신탁법 제22조). 이와 같은 취지에서 자산관리자가 위탁관리하는 유동화자산, 채권관리자가 위탁받아 관리하는 주택저당채권은 자산관리자 또는 채권관리자의 파산재단을 구성하지 않는다(자산유동화에 관한 법률 제12조 제1항, 주택저당채권유동화회사법 제10조 제5항).

48) 정준영, “파산절차가 계속중인 민사소송에 미치는 영향”, 재판자료 83집, 127. 이하

파산재단에 관한 소송에 관하여는 파산관재인이 당사자가 되고, 파산선고 전의 소송으로 계속중인 것의 소송절차는 중단되며, 원칙적으로 파산관재인이 이를 승계하게 된다.

나) 파산선고가 있으면 파산선고 당시 계속중이던 「파산재단에 관한 소송」은 파산선고로 인해 중단되며(민소 제217조), 소송대리인이 있는 경우에도 마찬가지이다.

사해행위취소소송(민법 제406조)은 파산자인 채무자를 피고로 하는 것은 아니지만, 그 소송의 결과는 파산재단에 직접적인 영향이 있고, 이를 부인소송으로 변경하여 파산관재인이 통일적으로 수행할 필요가 있으므로 중단된다(채무자회생법 제406조). 또한 채권자대위소송, 주주의 대표소송 등에 관하여는 명문의 규정은 없으나 위 사해행위취소소송과 마찬가지로 소송절차가 중단되고 파산관재인이 수계할 수 있다고 해석되고 있다.⁴⁹⁾ 행정소송도 토지수용을 다투는 소송 등과 같이 파산재단에 직접 영향을 미치는 것이면 중단된다. 나아가 소의 객관적 병합이 있는 경우 또는 본소에 대한 반소가 제기되어 있는 경우에는 파산재단에 한하여 소송절차가 중단된다. 소의 주관적 병합의 경우에는 공동소송인 중 파산선고를 받은 자의 소송절차만 중단된다.

다) 그러나 파산재단과 관계없는 소송, 예를 들어 개인파산의 경우 이혼 기타 신분관계에 관한 소송, 자유재산에 관한 소송, 법인파산의 경우 회사설립무효의 소송, 주주총회 결의의 효력에 관한 소송 등은 파산선고가 있어도 파산자가 여전히 당사자로 되는 것이므로 소송절차가 중단되지 않고, 자유재산에 관한 소송도 파산자가 그 관리 처분권을 잃지 않으므로 중단되지 않는다.

라) 파산재단에 속하는 재산 그 자체에 관한 소송은 파산관재인이 소송을 수계한다(채무자회생법 제347조). 수계신청은 파산관재인은 물론 상대방도 할 수 있다. 실무에서는 파산선고 직후 파산관재인으로 하여금 소송이 진행 중인 법원에 수계신청을 하도록 지도하고 있다.⁵⁰⁾ 파산선고 전부터 소송대리인이 선임되어 있던 경우에는 그 기초가 되는 위임계약은 파산선고로 실효하였고 대리권도 소멸하므로(민법 제690조 전문, 제128조 전문), 다시 위임계약을 체결하여야 한다.

2) 강제집행, 보전처분 등에 대한 효과

가) 파산선고에 의하여 파산채권자는 개별적인 권리행사가 금지된다(즉 개별집행이 금지된다). 파산선고 전에 파산채권에 기하여 파산재단 소속의 재산에 대하여 한

49) 서울지방법원실무연구회(주1), 45.

50) 서울지방법원실무연구회(주1), 46.

강제집행, 보전처분은 파산재단에 대하여는 그 효력을 잃는다(채무자회생법 제348조 제1항 본문). 이와 같이 파산채권은 파산절차에 의하지 않으면 권리를 행사할 수 없는바, 이러한 점에서 파산선고는 집행장애사유가 되고, 그에 따라 채무자의 파산선고 후의 새로운 강제집행은 허용되지 않으며, 그 신청은 각하된다. 파산선고가 있으면 포괄집행에 의하여 총 채권자의 공평한 만족을 도모해야 하기 때문이다.

따라서 파산관재인은 기존의 강제집행처분을 무시하고 파산재단 소속 재산을 파산법원의 허가를 얻어 자유로이 관리 처분할 수 있다.⁵¹⁾ 그러나 파산관재인이 종전의 강제집행절차를 속행하는 편이 신속하고 고가로 매각할 수 있다고 판단한 경우에는 그 강제집행절차를 스스로 속행할 수 있다(채무자회생법 제348조 제1항 단서). 이때 파산관재인은 집행기관에 대하여 채무자가 파산선고를 받았고 파산관재인이 선임된 사실을 알리고 소명자료를 첨부하여 강제집행절차를 속행하겠다는 취지의 신청을 하여야 한다.⁵²⁾

나) 다만 파산선고 전에 이미 집행이 완료된 경우에는 부인권 행사의 문제만 남고, 실효의 문제는 생길 여지가 없다. 동산·부동산의 집행은 배당액을 지급하거나 매각대금 또는 수익금을 교부함으로써 종료되고, 압류명령에 있어서는 압류채권자가 제3채무자로부터 지급을 받은 때 혹은 배당절차가 종료한 때이며,⁵³⁾ 전부명령에 있어서는 전부명령이 확정될 것을 조건으로 제3채무자에게 그 명령이 송달된 때 각 완료된다.⁵⁴⁾

다) 파산선고에 기한 강제집행 실효는 파산절차와의 관계에서 상대적으로 생기는 것이므로⁵⁵⁾ 압류의 단계에서 파산선고가 되었으나 파산관재인이 환가(현금화)하지 않은 채 파산이 해지되면, 집행채권자는 그대로 집행절차를 속행할 수 있다. 또한 실효한 가압류도 목적물이 파산자의 소유로 남아 있으면 부활한다. 파산선고와 동시에 파산절차가 폐지되는 경우(이른바, 동시폐지의 경우)에는 파산재단 자체가 처음부터 성

51) 다만 실무상 집행처분의 외관을 없애기 위하여 집행기관에 대하여 파산선고 결정 등본을 취소원인 서면으로 소명하여 사정변경을 이유로 하는 강제집행·보전처분의 집행취소신청을 하여야 한다. 부동산에 대한 가압류 또는 처분금지 가처분 등기는 집행법원의 등기말소촉탁에 의하여 말소할 수 있다.

52) 이 경우 집행기관은 일반채권자의 배당요구는 무시하고, 배당기일에는 별제권자에게 배당한 다음 집행비용을 포함한 잔금 전액을 파산관재인에게 교부해야 한다[정준영(주6), 196.].

53) 東京地裁債權執行等手續研究會, 債權執行の諸問題, 判例クイムズ사, 484.

54) 日東京高決 昭和 30(1955). 12. 26.(高民 8券 10号, 759.), 日東京高決 昭和 56(1981). 5. 6. (金融法務事情 979号, 54.); 東京地裁債權執行等手續研究會(주11), 484.

55) 서울지방법원실무연구회(주1), 48.

립하지 않으므로 채무자회생법 제348조가 적용되지 않는다. 따라서 이 경우에는 파산선고 전에 파산자 소유 재산에 관하여 진행 중이던 강제집행, 가압류, 가처분은 실효하지 않고 그대로 진행된다.

3) 담보권실행경매의 경우

파산재단 소속 재산에 관한 질권, 저당권 등의 담보권은 파산선고가 있어도 실효하지 않고, 채무자의 지위가 파산관재인에게로 승계되어 계속 진행된다(별제권, 채무자회생법 제411조, 제412조). 파산관재인은 이 경우 파산선고 및 파산관재인 선임 사실을 소명할 수 있는 자료를 첨부하여 담당 재판부에 신고하여야 한다.

4) 체납처분

파산재단 소속 재산에 대하여 조세 기타 국세징수법 또는 국세징수의 예에 의하여 체납처분을 한 경우에는 파산선고에 의하여 영향을 받지 않고 그대로 속행된다(채무자회생법 제349조). 조세채권은 재단채권으로써 수시변제를 받고(채무자회생법 제473조 제2호 본문, 제475조), 공익적 성격을 가진다는 점을 고려하여 파산선고 전에 착수한 것에 한하여 체납처분의 속행을 인정한 것이다. 파산선고 후에는 새로운 체납처분을 할 수 없다.⁵⁶⁾

2. 파산자의 신분 등에 대한 효과

파산선고로 인해 파산자 또는 그 대리인, 이사 및 이에 준하는 자는 파산관재인, 감사위원, 채권자집회의 요청에 의하여 파산에 이르게 된 사정, 파산재단, 환취권, 별제권, 파산채권, 부인권 등 파산에 관하여 필요한 설명을 할 의무가 있다(채무자회생법 제321조 제1항).

그리고 파산자등이 파산관재인에 대한 설명에 응하지 않거나 법원의 심문을 위한 소환에 응하지 않는 경우에는 구인할 수 있다(채무자회생법 제319조, 제423조). 또 파산관재인은 파산자에게 보내는 우편물이나 전보 등을 개파할 수 있다(채무자회생법 제484조 제2항). 그 외에 각종 법인 등은 파산선고를 받으면 해산되고, 파산자등은 사법상 후견인이 될 수 없는 등의 자격제한을 받게 된다.

56) 서울지방법원실무연구회(주1), 49.; 대법원 2003. 3. 28. 선고 2001두9486 판결【판결요지】파산법 제62조는 파산선고 전의 체납처분은 파산선고 후에도 속행할 수 있다는 것을 특별히 정한 취지에서 나온 것이므로 파산선고 후에 새로운 체납처분을 하는 것은 허용되지 아니한다는 것으로 해석함이 상당하고, 또한 파산법 등 관계 법령에서 국세채권에 터 잡아 파산재산에 속하는 재산에 대하여 체납처분을 할 수 있다는 것을 정한 명문의 규정이 없는 점 등을 종합하여 보면, 국세채권에 터 잡아 파산선고 후에 새로운 체납처분을 하는 것은 허용되지 아니한다.

3. 파산채권자에 대한 효과

가. 개별집행의 금지

파산선고에 의하여 파산채권자는 개별적인 권리행사가 금지되고, 파산절차에 참가하여서만 그 만족을 얻을 수 있다(채무자회생법 제424조). 즉 파산채권자는 그 채권을 일정 기간 내에 파산법원에 신고한 후, 채권조사기일에서의 조사를 거쳐 확정된 액 및 순위에 따라 배당을 받아야 하며, 파산자의 자유재산에 대하여 강제집행할 수도 없다. 파산채권에 기하여 가압류를 신청하는 경우에는 그 신청을 각하하여야 할 것이다. 이미 개시되어 있는 강제집행·보전처분은 앞서 보았듯이 실효한다(채무자회생법 제348조 제1항). 다만 파산재단 소속의 특정 재산에 대하여 담보권을 가지는 자는 별제권으로서 파산절차에 의하지 아니하고 채권의 만족을 얻을 수 있다(채무자회생법 제411조, 제412조).⁵⁷⁾

그러나 파산자의 보증인 또는 물상보증인에 대하여는 파산선고의 효력이 미치지 않으므로 이들에 대한 추심 또는 집행에는 아무런 영향이 없다(채무자회생법 제430조 제1항, 제3항 참조). 또한 어음소지인은 만기 전에도 인수를 위한 어음의 제시를 금지한 어음의 발행인이 파산한 경우 소구권을 행사할 수 있다(어음법 제43조 제3항).

나. 파산채권의 등질화

파산절차는 파산자의 모든 재산을 환가(현금화)하여 그 환가대금으로 파산채권에 대하여 금전에 의한 배당을 함으로써 채권자의 공평하고 평등한 만족을 도모하는 절차이므로 이를 위하여 파산선고가 있으면 금전에 의한 배당이 가능하도록 비금전채권은 금전으로 평가하고(금전화), 선고시에 변제기가 도래하지 않은 채권은 일률적으로 변제기가 도래한 것으로 취급한다(현재화). 위 금전화와 현재화를 아울러 파산채권의 등질화 또는 균질화라고 한다(채무자회생법 제425조, 4제26조).

4. 파산신청의 취하 불가

파산신청의 취하는 파산선고 전에 한하여 허용되며, 파산선고 후에는 모든 이해

57) 이 규정에 의해 파산관재인이 강제집행의 절차를 속행하는 때에는 비용은 이를 재단채권으로 하고 강제집행에 대한 제3자의의 소에 있어서는 파산관재인을 피고로 한다(채무자회생법 제348조 제2항).

관계인에게 효력을 미치므로 그 확정 전이라 하더라도 이를 취하할 수 없다.

Ⅲ. 파산재단에 속한 채권에 대한 압류의 경우

1. 압류명령 발령 후에 파산선고가 있었던 경우⁵⁸⁾

가. 집행이 완료된 경우

이미 집행이 완료된 경우에는, 채권자는 이미 변제를 받아버린 것이므로 앞서 본 바와 같이 채무자회생법 제348조의 적용이 없고, 따라서 집행절차가 소급하여 실효하지는 않는다. 여기서 집행의 완료시란, 이미 보았듯이 압류명령에 있어서는 압류채권자가 제3채무자로부터 지급을 받은 때 혹은 배당절차가 종료한 때이고, 전부명령에 있어서는 전부명령이 확정될 것을 조건으로 제3채무자에게 그 명령이 송달된 때를 말한다.

나. 집행이 계속되어 있는 경우

1) 학설의 대립

이에 대하여는 다음과 같이 학설이 나누어지고 있다.

가) 정지설⁵⁹⁾ : 이 설은 파산선고에 의해 강제집행은 당연히 실효하지만, 그것은 파산재단과의 관계에서 상대적인 실효이므로 이 경우 집행법원은 집행절차를 직권으로 정지할 수 있을 뿐이라고 보는 견해이다. 이에 따르면 개별집행금지의 취지는 파산선고 후에는 각 채권자의 공평한 만족을 위해 파산절차라는 포괄집행에 의해야 한다는 데에 있고, 파산절차가 아니라면 개별집행이 허용되지 않을 이유가 없기 때문에, 파산선고의 취소 또는 파산폐지의 경우에는 개별집행이 부활하게 된다.⁶⁰⁾ 그래서, 파산선고의 단계에서는, ㉠ 파산관재인이 강제집행절차의 속행을 구할 가능성이 있고, ㉡ 또한 후에 파산선고가 취소되든가 혹은 파산폐지의 결정이 되든가 하여 개별집행이 부활할 가능성도 있으므로 이러한 경우에 대비하여 채권집행사건을 종료시

58) 채권에 대해 담보권(예컨대, 질권 등)이 설정된 후 그 실행을 위해 채권압류명령을 발령받은 경우에는 그 후에 채무자가 파산선고를 받더라도 그에 영향 받음이 없이 그 절차를 속행할 수 있으므로(별제권, 채무자회생법 제411조, 제412조), 아래에서 살펴보게 되는 파산선고가 채권압류에 대해 미치는 영향을 살펴볼 때에도 이러한 경우는 논의의 실익이 거의 없다. 따라서 이에 대하여는 상론하지 않는다.

59) 鈴木忠一 = 三ヶ月章 責任編集, 注解民事執行法(1), 第一法規出版株式會社(昭和60), 518.

60) 東京地裁債權執行等手續研究會(주11), 484.

키기보다는 절차를 정지해두는 것이 타당하다고 보는 것이다.

나) 취소설⁶¹⁾ : 이 설은, 위 정지설은 부동산집행에 대하여만 타당한 것으로 보고, 채권집행의 경우에는 파산선고 확정시에 취소결정에 의해 확정적으로 종료한다고 보는 견해이다. 이에 의하면, 절차가 병존하지 않고 개별집행의 부활도 없으므로 제3채무자에 대하여 그 권리관계의 귀속이 명확하게 된다는 장점이 있다. 이 견해의 근거는 다음과 같다. 즉 부동산집행의 경우에는 절차가 부동산의 평가, 매각, 배당등과 같이 순차진행하고, 파산선고나 파산폐지 등이 등기라는 명확한 공시수단에 의해 누구에게도 명확한 것이므로 위 정지설이 타당할 수 있다. 그러나 채권의 경우에는 환가(현금화)에 해당하는 것으로서 채권자의 추심, 제3채무자의 변제, 공탁이 있을 뿐이고, 게다가 파산선고, 폐지의 사실 및 그 효과에 대한 명확한 공시수단이 없으므로 제3채무자가 변제해야할 상대방이 누구인가를 확정하기가 곤란하다. 따라서 이와 같은 절차의 특성 또는 제약을 감안하면 채권집행의 경우에는 파산폐지에 의해 부활하지 않는다고 보는 것이 타당하다는 것이다.

이제 보전대, 위 견해 중 취소설에 의할 경우 그 절차가 제3채무자에 대하여도, 또 집행법원에 대하여도 명쾌한 이점이 있다. 또한 채권집행의 경우 파산관재인은 파산절차 중에도 스스로 추심이 가능하며, 제3채무자가 공탁한 공탁금을 지급받을 수도 있으므로 파산관재인의 절차속행이나 파산폐지 후의 절차부활의 장점이 있는 경우는 실제상 거의 없기는 하다. 그러나 취소설에 따르면, 예컨대 추심소송이 계속되어 있는 경우에 파산관재인이 소송을 수계할 근거가 없게 되고, 파산관재인이 공탁금을 지급받을 수 없는 사이에 폐지되어버리는 경우도 있을 수 있는바, 위와 같이 취소설을 취함으로써 절차의 속행, 부활의 가능성을 아예 없애버리는 것이 과연 적절한지에 관해서는 의문의 여지가 있다. 따라서 이 문제는 이후 계속 검토를 요하는 것이지만, 이하에서는 위 정지설을 기초로 하여 논의를 전개하기로 한다.

2) 절차

이 경우, 파산관재인이 법원에 대해 파산선고결정의 정보를 제출하여 직권의 발동을 촉구하고, 이에 따라 집행법원은 직권에 의해 절차를 정지하게 될 것이다. 그 이후 법원사무관등은 채권자 및 제3채무자에 대해 절차가 정지된 사실, 채권자의 추심이나 제3채무자의 압류채권자에의 지급이 금지된 사실 등에 대해 통지를 해야 할 것이다(민집규 제161조 제1항 참조).

61) 吉野 衛·三宅弘人 共著, 香川保一 監修, 注釋民事執行法(2, きんざい, 平成 7年(1995), 597.

3) 공탁금의 처리

제3채무자가 파산재단에 속해야 할 채권에 대해 집행공탁(민집 제248조 참조)을 한 경우에는 파산재단의 관리처분권을 파산관재인이 갖고 있으므로 집행법원은 위 공탁금을 파산관재인에게 지급해야 한다. 그 지급방법에 대하여는 ① 파산관재인에게 공탁서등을 교부하는 방법⁶²⁾과 ② 집행법원이 공탁관에게 지급위탁을 하는 방법⁶³⁾등을 생각해 볼 수 있으나, 후자의 방법이 더 편의로울 것이다.

2. 압류명령발령 전에 파산선고가 있었던 사실이 발령 후에 판명된 경우

가. 절차의 취소

1) 이 경우에는 본래의 채권압류명령은 그 발령이 허용되지 않았던 것이고, 또 파산폐지에 의해 위 채권압류의 절차가 부활할 여지가 없다. 이 경우도 절차가 정지될 뿐이라는 견해가 있을 수 있지만, 압류명령 발령시에 파산선고 사실이 판명될 경우 그 신청이 각하되는 것(압류명령에 대해 파산선고는 집행장애사유이다)을 생각해 보면 이러한 해석은 곤란할 것이다.⁶⁴⁾ 따라서 파산선고(동시폐지의 경우를 제외하고)의 확정이었다면 사실이 명확하게 되면 법원은 압류명령을 취소해야 한다.

그리고 이때에 압류명령등은 당연무효이므로 취소할 여지가 없다는 견해도 있지만,⁶⁵⁾ 집행절차가 확정적으로 종료할 경우에 외형상 그 명령이 존재하는데도 어떤 결정도 하지 않는 것은 절차의 명확성과 안전성을 결하게 되고, 또 당사자의 보호를 위해서도 타당하지 않으므로 취소가 필요하다고 본다.⁶⁶⁾

62) 이 경우 파산관재인은 공탁서교부신청서(별지서식 [11-3] 공탁서교부신청서), 공탁서교부증명신청서([11-4] 공탁서교부증명신청서 및 [11-5] 공탁서교부증명), 수서([11-6] 영수증) 등을 갖추어 제출하면 되고, 이러한 서류가 제출되면 그 절차를 명확하게 하기 위해 공탁서교부신청서에 집행법관이 결제인을 날인한 다음 법원사무관등이 파산관재인에게 공탁서 및 공탁서교부증명서를 교부하면 될 것이다.(제11장 말미 수록)

63) 이 경우 파산관재인은 신청서(별지서식 [11-1] 파산관재인에게 공탁금의 지급을 구하는 신청서), 수서([11-6] 영수증), 파산법원이 발행한 파산관재인 자격증명서 겸 인감증명서(파산선고 일시가 기재되어 있어야 하고, 자격증명서와 인감증명서는 별개의 서면이어도 됨), 우편비용, 파산선고 후 취득한 재산(이른바, 新得財産)이 있고 이에 대해 파산자의 동의하에 파산재단에 혼입된 경우에는 파산자의 동의서([11-2] 동의서)와 파산자의 인감증명서 등을 첨부하여 제출하고, 이 서류가 제출되면 절차를 명확하게 하기 위해 신청서에 집행법관의 결제인을 받은 다음, 법원사무관등이 공탁관에게 지급위탁을 하면 될 것이다.(제11장 말미 수록)

64) 즉 압류명령을 발한 후 정지해두는 식의 처리는 허용되지 않는다.

65) 日東京高決 昭和 30(1955). 12. 26.(高民 8卷 10号, 758.), 日東京高決 昭和 56(1981). 5. 6.(東高民時報 32卷 5号, 11.) 등

66) 東京地裁債權執行等手續研究會(주11), 486.

2) 제3채무자가 이미 채무액을 공탁한 경우에는 어떻게 할 것인가.

이에 대하여는 이 경우에도 그 부분에 대해 취소된다는 견해가 있을 수 있으나, 제3채무자가 채무액을 공탁한 후에는 압류명령이 장래에 향하여 그 효력을 상실하고 소멸하게 되어(이에 관하여는 제8장 집행공탁 제2절 Ⅷ. 2. 참조), 그 취소의 여지가 없으므로 이미 공탁된 부분에 대하여는 취소되지 않는다고 봄이 타당할 것이다. 다만 어느 견해에 의하더라도 제3채무자가 한 공탁의 효력은 유지될 것이다.

3) 또한 이미 집행이 종료된 경우에는 그 효력은 파산재단에 대한 관계에서 상대적으로 무효이지만, 이제는 집행취소의 여지가 없으며,⁶⁷⁾ 폐지결정이 확정된 경우에는 하자가 치유된 것으로 보아 절차를 속행하는 것이 좋을 것이다.⁶⁸⁾

나. 절차의 내용

파산선고의 사실은, 당사자로부터 신청을 요하는 것이 아니라 어떠한 사정으로 그것이 집행법원에 판명된 때에는 직권으로 이를 고려해야 하는 집행장애사유인 것을 감안하면, 집행법원은 파산선고의 확정을 기다려 직권으로 압류명령을 취소해야 하는 것으로 해석된다.⁶⁹⁾ 그러나 실제상으로는 파산관재인등이 파산선고결정정보 및 확정증명등을 제출하여 법원에 대해 직권발동을 촉구하는 것이 필요하다고 본다.⁷⁰⁾

위 취소결정은, 압류채권자 및 채무자(파산관재인)에 대하여 고지되고(민집규 제7조 제1항 제3호), 제3채무자에 대하여는 법원사무관등으로부터 통지된다(민집규 제160조 제1항). 그리고 위 취소결정에 대하여는 즉시항고가 가능하다(민집 제17조). 다만 파산관재인이 압류명령에 대한 즉시항고의 신청기간 내에 민사집행법 제227조 제4항에 의한 즉시항고로서 채권압류명령의 취소를 신청한다면, 그 신청의 이익이 없다고 보기는 어려울 것이다.

다. 공탁금의 처리

제3채무자가 위 취소결정 전에 공탁을 해버린 경우에는 그 관리처분권이 파산관

67) 鈴木忠一 外, 위 注解民事執行法(4), 518, 519.

68) 東京地裁債權執行等手續研究會(주11), 486.

69) 東京地裁債權執行等手續研究會(주11), 486-487.

70) 파산선고의 존재는 집행절차의 정지, 취소에 의하여 이익을 받을 파산관재인, 파산자가 가장 잘 알고 있는 것이고, 반면 집행법원에 대해 방대한 수의 파산공고로부터 채무자가 파산선고받은 사실의 유무를 조사시키도록 한다는 것은 불가능을 강요하는 것이라고 볼 수 있다. 파산선고사실의 유무에 대하여는 파산관재인등이 직권발동을 촉구해야 할 것이다. 그리고 이른바 신득재산(新得財産)에 속한 채권에 대한 압류의 경우에도 동일하다.

채인에게 있다고 볼 것이므로 집행법원의 지급위탁에 의해 파산관재인에게 공탁금을 지급해야 할 것이다. 취소결정 후 제3채무자에 대해 통지하기 전에 공탁한 경우에도 그 공탁으로 인한 변제공탁효를 인정해야 할 것이고, 따라서 이 경우 공탁금의 지급도 위와 동일하게 집행법원의 지급위탁에 의해 파산관재인에게 행해져야 할 것이다.^{71) 72)}

3. 채무자의 파산사건이 동시폐지사건인 경우

파산선고시에 파산재단으로써 파산절차의 비용을 충당하기에 충분하지 않다고 인정되는 경우에는 파산선고와 동시에 파산폐지의 결정을 하게 되는데(채무자회생법 제317조 제1항), 이를 실무상 동시폐지(同時廢止)라고 하며, 선고 후에 폐지되는 이시폐지(異時廢止)와 구별된다. 이러한 동시폐지의 결정이 있으면 파산절차는 장래를 향해 해지된다.

이와 같이 파산사건이 파산선고와 동시에 폐지된 경우에는 채권압류명령을 취소하는 등의 여지가 없다. 파산폐지에 의해 파산절차는 종료하게 되고, 파산자는 재산의 관리처분권을 회복하게 된다. 따라서 채권자는 개별집행금지의 제한 없이 파산자의 재산에 대해 강제집행이 가능하게 된다. 그리하여 동시폐지사건의 경우에는 결과로서 집행절차에는 영향을 미치지 않는 것으로 된다.

4. 동시폐지 후 면책결정이 되어 확정된 경우

가. 면책결정의 효과 등

1) 파산법상 면책이란, 자연인 파산자에 대하여 파산절차에 의하여 배당되지 아니한 잔여 채무에 대하여 변제책임을 면하는 것을 말하는데(채무자회생법 제566조 본문), 현행법은 이를 파산절차와는 별개의 제도로서 규정하고 있다.

파산법원은 면책불허가 사유가 없거나 있더라도 재량면책을 하는 경우 면책허가 결정을 하게 되는데, 그 결정은 확정되어야 효력이 발생한다(채무자회생법 제565조). 또 면책허가결정은 형성적 효과를 그 내용으로 하고 달리 소급효를 인정하는 규정도 없으므로 소급효가 인정되지 않는다.⁷³⁾

면책을 받은 파산자는 파산절차에 의한 배당을 제외하고 파산채권자에 대한 채

71) 東京地裁債權執行等手續研究會(주11), 487.

72) 별지서식 [11-7] 신청서(채권압류명령의 취소에 의한 지급위탁) 참조(제11장 말미 수록)

73) 서울지방법원실무연구회(주1), 380.

무의 전부에 관하여 그 책임이 면제되고(채무자회생법 제566조 본문), 자연채무로 된다는 것이 일반적 견해이다.⁷⁴⁾ 즉 통상의 채권이 가지는 소제기의 권능과 집행력을 상실하며, 단순히 임의의 변제를 청구할 수 있는 권능 및 변제에 의한 급부를 보유할 수 있는 권능만이 남게 된다. 따라서 파산자가 면책허가를 받았더라도 그 후의 임의의 변제는 유효한 변제로서 채권자의 부당이득 문제는 생기지 않는다. 또한 면책허가 결정이 있으면 파산자는 당연히 복권되고(채무자회생법 제358조 제1항 제1호), 공·사법상 가해진 신분상의 제한이 소멸된다.⁷⁵⁾

2) 다만 채무자회생법 제566조 단서는 파산채권 중 면책의 효력을 부여하는 것이 여러 이유에서 부적당한 채권들, ① 조세 ② 벌금·과료·형사소송비용·추징금 및 과태료 ③ 채무자가 고의로 가한 불법행위로 인한 손해배상 ④ 채무자가 중대한 과실로 타인의 생명 또는 신체를 침해한 불법행위로 인하여 발생한 손해배상 ⑤ 채무자의 근로자의 임금·퇴직금 및 재해보상금 ⑥ 채무자의 근로자의 임치금 및 신원보증금 ⑦ 채무자가 악의로 채권자목록에 기재하지 아니한 청구권. 다만 채권자가 파산선고가 있음을 안 때에는 그러하지 아니하다. ⑧ 채무자가 양육자 또는 부양의무자로서 부담하여야 하는 비용 등을 이른바 비면책채권으로서 면책으로부터 제외하고 있다.⁷⁶⁾

나. 동시폐지 후 면책결정 확정시까지의 채권압류의 효력

우선, 동시폐지결정이 확정된 때로부터 면책결정의 확정시까지 사이에는 강제집행이 가능하고, 그것에 의해 지급받은 부분에 대하여도 부당이득이 되지 않는다고 해석되고 있다.⁷⁷⁾

그런데 면책확정 전에 행해진 강제집행이 면책확정에 의해 어떠한 영향을 받는가가 문제로 되는데, 면책확정은 청구이의사유라고 보는 것이 상당하고, 따라서 가령 면책결정정본이 집행법원에 제출되어도 배당절차를 정지할 수 없다 할 것이다.⁷⁸⁾ 이

74) 서울지방법원실무연구회(주1), 381.

75) 그러나 일부면책결정은 동시에 일부불허가결정이기도 하므로 확정되더라도 채무자회생법 제574조 제1항 제1호에서 정하는 「면책의 결정이 확정된 때」에 해당하지 아니하여 당연히 복권되지는 않는다. 이 경우에 파산자는 일부 면책되지 않은 채무를 변제하거나 채권자의 면제 등으로 그 책임을 면하였다는 점을 증명하여 복권절차를 밟아야 한다. 그리고 자연인이 파산선고를 받으면 금융기관이 관리하는 개인신용정보에 적색거래자로 분류되어 일정한 기간 각종 금융거래상의 불이익을 받게되나, 이는 파산에 따른 법률상의 효과가 아니므로 면책결정이 확정된다고 해서 당연히 면할 수 있게 되는 것은 아니다.

76) 별제권도 당연히 비면책채권이다.

77) 日最判 平成 2(1990). 3. 20.(判時 1345, 68) 참조

78) 近藤基 編, (實務)債權配當の基本問題, 民事法研究會(平成 13), 286.

경우 배당을 정지하기 위해서는 청구이의소송을 제기하고 그것에 기초한 집행정지결정을 얻어 이를 집행법원에 제출하든가 혹은 배당이의에 의하는 수밖에 없다고 본다. 그리고 배당을 정지한 후에 압류채권자 전원이 채권압류명령을 취하한 때에는 공탁금은 채무자(파산자)에게 지급해야 할 것이다.

IV. 파산선고 후 취득한 재산인 채권에 대한 압류의 경우

여기서는 파산선고 후에 파산자가 새로 취득한 재산[이른바, 신득재산(新得財産)]에 대하여 압류가 있는 경우에 관해 살펴보기로 한다.

1. 강제집행 가능 여하

채권자가 파산선고 전에 취득한 채권을 청구채권으로 하여 파산선고 후에 파산자가 새로 취득한 신득재산(新得財産)에 대하여 강제집행을 하는 것이 허용될 것인가.

이에 대하여는 채무자회생법 제348조 제1항이 「파산재단에 속한 재산」이라는 제한적 문언을 사용하고 있음을 들어 이를 긍정하는 견해⁷⁹⁾ 80)가 있으나, 우리 채무자회생법이 취하고 있는 고정주의 및 면책주의 등의 취지에 비추어보면 이를 부정함이 타당하다고 본다.⁸¹⁾

따라서 위 신득재산(新得財産)에 대한 새로운 채권집행의 신청은 각하(또는 기각)해야 한다. 다만 이는 파산절차 중(파산절차의 종료시까지)에는 개별집행이 금지된다는 것에 불과하므로 파산폐지결정이 확정된 후에는, 면책절차 중이어도 파산절차는 이미 종료한 것이기 때문에 강제집행이 허용되고, 또한 집행종료 후에 면책결정이 있어도 부당이득이 되지 않는다고 볼 것이다.⁸²⁾

2. 채권압류명령이 발령된 경우

가. 압류명령발령 후에 파산선고가 있었던 경우

이는 실제상 신득재산(新得財産)에 대하여 채권압류명령을 발령한 후에 파산선고

79) 齋藤常三郎, 比較破産法論, 有斐閣(昭和15), 304.

80) 새로 취득한 재산에 대하여 가압류를 할 수 있다는 것에는 日大判 昭和 2(1927). 4. 8.(新聞 2672, 8)가 있다.

81) 中田淳一, 破産法・和議法, 有斐閣(1959), 203.; 日最判 平成 2(1990). 3. 20. 昭和 62年(才) 第717号 事件(判タ 725号, 59.) 등

82) 위 日最判 平成 2(1990). 3. 20. 昭和 62年(才) 第717号 事件(判タ 725号, 59.) 및 日最判 平成 2(1990). 3. 20. 昭和 63年(才) 第1566号 事件(判タ 725号, 59.) 등

가 있었던 경우에 대한 것이다. 이에 관한 전형적인 예로는, 급료채권등의 계속적급부채권을 피압류채권으로 하여 채권압류명령이 발령된 후 파산선고가 있고 위 압류가 파산선고 후 다음 기(期)의 급료에 걸쳐 있는 경우를 들 수 있다.

1) 집행이 완료된 경우

위 Ⅲ. 1. 가.에서 보았듯이 이미 집행이 완료된 경우에는 파산선고가 있더라도 그 집행이 소급하여 실효하는 것은 아니다.

2) 집행이 계속되고 있는 경우 압류명령의 효력 등

가) 이미 폐지결정이 확정된 경우

전술한 대로, 동시폐지의 경우 또는 폐지결정확정 후 면책결정확정 전인 경우에는 개별집행이 허용되므로 절차는 취소도 정지도 되지 않고 속행되고 이미 공탁된 돈에 대하여는 배당등 절차가 행해지며, 잉여금만이 채무자에게 교부된다.

나) 파산절차 속행중인 경우

(1) 집행절차의 취소 : 신득재산(新得財産)에 대한 채권압류의 경우에는 파산재단에 속하는 채권에 대한 압류의 경우와 달리, 압류명령을 취소해야 하고 이미 공탁된 돈은 파산자가 지급을 받아야 할 것이다.

그 이유는 다음과 같다. 즉 정지설에 의하면 당해 개별집행을 한 채권자에 대한 배당등 액은 유보공탁되고(민집 제256조, 제160조 제1항 제3호 유추), 파산절차 중에는 파산자에게 지급되지 않는다. 그리고 파산절차가 폐지등으로 인해 종료한 때는 채권자가 그 공탁금을 지급받게 되기 때문에[위 (가)항 참조], 결국 파산자는 신득재산(新得財産)에 속한 채권의 변제를 받을 수 없는 것으로 된다. 그러나 파산재단에 속한 채권에 대하여는 각 채권자 사이의 공평을 위해 포괄집행을 해야 하는 것이므로 개별집행이 허용되지 않음⁸³⁾에 대해, 신득재산(新得財産)에 속한 채권에 대하여는 개별집행뿐만 아니라 파산절차에 의해서도 집행할 수 없고, 이 경우 개별집행금지의 취지는 오로지 파산자의 갱생을 위해 신득재산(新得財産)을 파산자의 자유로운 관리처분에 위탁하는 취지 외에는 없다. 이와 같은 취지에 비추어 보면, 집행법원이 파산절차의 부활가능성에 대비하여 개별집행절차를 유지하는 것, 즉 집행채권자를 위해 파산자의 신득재산(新得財産)에 대한 관리처분권 행사의 자유를 제한해버리는 것은 타당하지 않다. 따라서 신득재산(新得財産)에 속한 채권을 압류한 경우에는 직권으로 그 집행절차를 취소해야 하는 것이다.

83) 말하자면, 집행방법이 개별집행에서 포괄집행으로 바뀌어짐에 불과하다.

그리고 이 경우 파산선고가 있었던 단계에서는 파산선고취소의 가능성도 있기 때문에 절차를 정지함에 그치고 파산선고가 확정된 때에 법원이 직권으로 압류명령을 취소하게 된다. 이 경우 개별집행은 당연히 실효하는 것이므로 그 취소는 필요하지 않다는 견해도 있을 수 있으나, 이는 앞서 보았듯이(Ⅲ. 2. 가. 참조) 그 절차를 불명확하게 하고 관계당사자의 보호에도 문제가 있으므로 타당하지 않다고 본다. 또한 이미 제3채무자가 공탁한 경우 및 집행이 종료한 경우 등의 취급에 대하여는 위 Ⅲ. 2. 가. 이하와 동일하므로 이를 참조하면 될 것이다.

(2) 절차 : 이 경우 파산자 또는 파산관재인이 파산선고서정보 및 그 확정증명을 집행법원에 제출하여 직권발동을 촉구하고, 집행법원이 이에 따라 취소결정을 하게 될 것이다. 그리고 이 경우에도 파산이 폐지되어 있을 가능성이 있고, 파산자가 신득재산(新得財産)의 파산재단에의 편입을 승낙하였을 경우도 있을 수 있으므로 집행법원으로서의 취소결정 전에 파산관재인에게 통지하여 확인해 보는 것이 상당할 것이며, 위 취소결정의 사실을 채권자·제3채무자에 대하여 고지·통지하는 것(민집규 제7조 제1항 제3호, 제160조) 외에 나아가 파산관재인에게 위 결정이 있었던 사실을 통지하여 즉시항고의 기회를 주는 것이 타당할 것이다.

(3) 불복신청 : 채권자가 이 취소에 대하여 불복이 있는 경우 그에 대한 불복신청은 어떠한 방법에 의해야 하는가.

민사집행법 제227조 제4항이 정하는 즉시항고는 명령 송달 후의 기간제한이 있을 뿐만 아니라 이는 본래 압류명령의 발령시에 하자가 있는 경우를 예정하고 있는 것이지 이와 같이 압류명령이 후발적으로 실효하는 경우를 예정하는 것은 아니라고 해야 한다.

따라서 위 취소결정은 파산선고의 확정이라는 집행장애사유의 존재에 의해 그 절차를 취소하는 것이므로 민사집행법 제17조에 따라 즉시항고가 허용된다고 볼 것이며,⁸⁴⁾ 그와 달리 이 경우를 민사집행법 제50조가 정하는 취소문서 제출의 경우에 유추하여 그에 따라 즉시항고가 허용되지 않는다(민집 제50조 제2항, 제17조)고 하는 것은 타당하지 않다고 생각한다. 신득재산(新得財産)에 대한 채권압류의 경우 취소의 판단은 이미 말한 대로 민사집행법 제50조가 예정하는 것과 같이 취소를 해야 하는 것이 문서에 의해 명백한 경우만에 한정되는 것은 아니기 때문이다.

(4) 공탁금의 처리 : 제3채무자가 공탁한 경우에는 - 위 Ⅲ. 2. 다.에서 서술한

84) 東京地裁債權執行等手續研究會(주11), 490.

것과 동일하게 - 취소결정 전의 공탁인 경우에는 파산자에의 지급위탁에 의해 공탁금을 파산자에게 지급해야 하고, 취소결정 후 통지 전의 공탁에 대하여도 그 변제공탁효는 여전히 유지되므로 파산자에게 지급위탁을 해야 할 것이다.

(5) 신득재산(新得財産) 여부의 판단이 문제되는 경우 : 급료채권에 대한 압류명령의 발령 후에 파산선고가 있었지만, 공탁된 각 기(期)의 급료채권이 파산선고의 전 후에 걸쳐 있는 경우에는 어떻게 될 것인가.

이와 같은 계속적 급부채권의 압류 사례에서 각 期의 채권이 파산재단에 속하는가 아니면 신득재산(新得財産)에 속하는가의 구별은 파산자의 채권취득의 원인이 파산선고 후의 것인가 아닌가를 기준으로 정해진다. 따라서 급료채권의 경우에 파산선고 후의 노동의 대가(그리고 민사집행법 제246조에서 압류가능한 부분)에 한해, 신득재산(新得財産)이라고 해야 한다.⁸⁵⁾ 그리하여, 月의 도중에 파산선고가 있었던 경우에는 1개의 공탁 가운데에 파산재단 부분과 신득재산(新得財産) 부분이 혼재되어 있을 수 있는데, 이 경우에는 일할계산에 의해 파산재단 부분과 신득재산(新得財産) 부분으로 나누어, 그 각각에 대해 지급위탁을 하는 것이 원칙이다. 이때에 당해 파산선고일을 위의 경우 중 어디에 속한다고 볼 것인가가 문제되지만, 위 파산선고일이 파산선고보다 선행하고 있음이 명확하다고 볼 수 없으므로 이는 신득재산(新得財産) 부분으로 봄이 적절할 것이다.^{86) 87)}

그러므로 이 경우 급료채권 중 파산재단에 속한 부분에 대하여는, 절차를 정지한 후 공탁금을 파산관재인에게 지급위탁의 방법으로 지급하고, 신득재산(新得財産)에 속한 급료채권에 대하여는 압류명령을 취소하여 취소결정의 통지시까지 된 공탁금을 파산자에게 지급위탁해야 할 것이다.

나. 압류명령발령 전에 파산선고가 있었던 것이 발령 후에 판명된 경우

이 경우 본래 위 압류명령은 그 발령이 허용되지 않았던 것이므로 파산선고의 사실이 명확하게 되면 위 압류명령을 직권으로 취소해야 한다. 그러나 파산자가 민사집행법 제227조 제4항에 따라 압류명령에 대해 즉시항고를 신청해 두었다면 그 신청의 이익을 긍정해도 될 것이다. 이때 집행법원은 재도의 고안에 의해 위 압류명령을

85) 中田淳一(주39), 89.; 近藤基 編(주36), 283-284.

86) 近藤基 編(주36), 284.

87) 다만 실무상, 新得財産에 대하여는 대부분 파산자의 동의를 얻어 이를 파산재단에 혼입하는 것이 통례라고 보여지므로 위와 같이 일할계산을 하는 예는 거의 없을 것이다.

취소할 수도 있을 것이다.

다만 이미 파산폐지의 결정이 확정되어 있는 경우에는, 이제는 그 하자가 치유된 것으로 보아 그 절차를 속행함이 상당할 것이다. 압류명령을 취소한 경우, 제3채무자가 이미 공탁한 때에는 위 Ⅲ. 2. 다.에서 본 바와 같이 집행법원은 파산자에게 공탁금을 지급하는 것이 상당하므로 당해 부분에 대하여는 파산자에게로 지급위탁을 해야 한다.

[11 - 2] 동의서

동 의 서

파산자 ○ ○ ○ (인)
 ○○시 ○○구 ○○동 32-1

귀 법원 2018타채○○○호 채권압류명령신청사건에 대하여, 제3채무자가 공탁한 공탁금 가운데, 파산자의 신득재산(新得財産)에 대하여도 파산재단에 혼입시키는 것에 동의합니다.

20 . . .

○○ 지방법원 민사 제○○단독 귀중

첨부서류 인감증명서 1통

[11 - 3] 공탁서교부신청서

공탁서교부신청서

채무자 파산자 ○ ○ ○
 파산관재인 △ △ △(인)
 전화 02 - ○ ○ ○ ○ - ○ ○ ○ ○
 FAX 02 - ○ ○ ○ ○ - ○ ○ ○ ○

귀 법원 2018타채○○○○호 채권압류명령신청사건에 대하여, 채무자는 파산선고를 받아 본직이 파산관재인으로 선임되었습니다.

그러므로 파산관재인에 대하여, 제3채무자 ○○○으로부터 제출된 공탁서를 교부해주시기 바랍니다.

20 . . .

○○ 지방법원 민사 제○○단독 귀중

(주) 공탁서 및 공탁서교부증명서의 우송을 희망하는 경우에는 우송용봉투(반송용 우표를 첨부한 것)를 별도 제출하여야 한다.

[11 - 4] 공탁서교부증명신청서

공탁서교부증명신청서

채무자 파산자 ○ ○ ○
 파산관재인 △ △ △(인)
전화 02 - ○ ○ ○ ○ - ○ ○ ○ ○
FAX 02 - ○ ○ ○ ○ - ○ ○ ○ ○

귀 법원 2018타채○○○○호 채권압류명명신청사건에 대하여, 채무자가 파산선고를 받았기 때문에 제3채무자 ○○○으로부터 제출된 별지목록 기재의 공탁서가 파산관재인에게 교부된 것을 증명해주실 것을 신청합니다.

20 . . .

○○ 지방법원 민사 제○○단독 귀중

(별지공탁목록 기재 생략)

(주) 공탁서교부증명서제출시에 그와 동시에 증명신청서도 제출하는 것이 좋을 것이다.

[11 - 5] 공탁서교부증명신청서

공탁서교부증명신청서

채무자 파산자 ○ ○ ○
 파산관재인 △ △ △(인)
전화 02 - ○ ○ ○ ○ - ○ ○ ○ ○
FAX 02 - ○ ○ ○ ○ - ○ ○ ○ ○

귀 법원 2018타채○○○○호 채권압류명령신청사건에 대하여, 채무자가 파산선고를 받았기 때문에 제3채무자 ○○○○로부터 제출된 별지목록 기재의 공탁서가 파산관재인에게 교부된 것을 증명해주실 것을 신청합니다.

20 . . .

○○ 지방법원 민사 제○○단독 귀중

위와 같은 사실을 증명합니다.

20 . . .

○○ 지방법원 민사 제○○단독
법원사무관 ○ ○ ○ (인)

(별지공탁목록 기재 생략)

[11 - 6] 영수증

영 수 증

채무자 파산자 ○ ○ ○
 파산관재인 △ △ △(인)
전화 02 - ○ ○ ○ ○ - ○ ○ ○ ○
FAX 02 - ○ ○ ○ ○ - ○ ○ ○ ○

아래의 서류를 수령하였습니다.

20 . . .

○○ 지방법원 민사 제○○단독 귀중

- 아 래 -

- | | |
|-------------|----|
| 1. 공탁서교부증명서 | 1통 |
| 2. 공탁서 | 1통 |

[11 - 7] 신청서(채권압류명령의 취소에 의한 지급위탁)

신 청 서

채무자 주식회사 ○ ○
 대표이사 △ △ △(인)

아래 채권압류명령은 모두 취소에 의해 종료하였으므로 채무자에 대한 공탁금교부절차를 실시해주시기 바랍니다.

20

○○ 지방법원 민사 제○○단독 귀중

- 아 래 -

○○ 지방법원 2017타채○○호 채권압류명령사건

○○ 지방법원 2017타채○○호 채권압류명령사건

영 수 증

아래 서류를 수령하였습니다.

20

채무자 주식회사 ○ ○

 대표이사 △ △ △(인)

○○ 지방법원 민사 제○○단독 귀중

- 아 래 -

증명서(원) 통